

הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137

סימן א: הדין עובר לתיקון מס' 137

לפני תיקון מס' 137, עבירות ההמתה בחוק הישראלי כללו עבירה של גרימת מוות ברשלנות שדינה שלוש שנות מאסר;¹⁰¹⁴ עבירת הריגה המקיפה מקרי המתה מתוך מחשבה פלילית (החל בקלות דעת וכלה בכוונה), ואשר דינה עשרים שנות מאסר;¹⁰¹⁵ עבירת רצח שדינה מאסר עולם כעונש חובה;¹⁰¹⁶ וכללה כמה מקרים ספציפיים – המתה בכוונה תחילה,¹⁰¹⁷ המתה קרוב משפחה בסדר עולה (אב, אם, סב וסבתא)¹⁰¹⁸ והמתה בתוך ביצוע עבירה אחרת או בעת הכנות לביצועה או בניסיון לברוח או להימלט מעונש בגינה.¹⁰¹⁹ לצידה של עבירת הרצח הייתה הוראה שאפשרה הטלת עונש מופחת במקרים של המתה המתעלל בידי קורבן ההתעללות או בן משפחתו, המתה בידי עושה בעל הפרעה נפשית חמורה והמתה במצב שבו המעשה חרג במידה מועטה מתנאי הסבירות הנדרשת לשם תחולת הסייגים של הגנה עצמית, צורך וכורח.¹⁰²⁰ לצד עבירות אלו התקיימה עבירה ספציפית של המתה תינוק¹⁰²¹ ועבירות נגזרות ספציפיות של ניסיון לרצח¹⁰²² ושל שידול וסיוע להתאבדות.¹⁰²³ עבירת גרם מוות ברשלנות היא עבירה מיוחדת, הצדקת קיומה ברורה, והיא תידון בהמשך.¹⁰²⁴ אין חולק שעבירות של גרימת מוות במחשבה פלילית (על כל צורותיהן) בדין הישראלי שקדם לתיקון מס' 137 היו טעונות תיקון מקיף, והדברים מצאו ביטוי אקטואלי גם בקריאתם של השופטים לוין ובייסקי להכיר במודל של האחריות המופחתת,¹⁰²⁵ בדבריו של הנשיא (בדימוס) ברק שקראו

1014 ס' 304 לחוק העונשין.

1015 ס' 298 לחוק העונשין.

1016 ס' 300(א) לחוק העונשין.

1017 ס' 300(א)(2) לחוק העונשין בצירוף סעיף 301 לחוק העונשין.

1018 ס' 300(א)(1) לחוק העונשין.

1019 ס' 300(א)(4) וסעיף 300(א)(3) לחוק העונשין.

1020 ס' 300 לחוק העונשין.

1021 ס' 303 לחוק העונשין.

1022 ס' 305 לחוק העונשין.

1023 ס' 302 לחוק העונשין.

1024 ראו בהמשך הפרק השביעי.

1025 ראו ע"פ 870/80 לדאני נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1) 29, 38–39 (1981); ע"פ 647/85 קיסר נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(1) 347, 354 (1987); ע"פ 747/86 איזמן נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(3) 447, 463 (1988).

למחוקק לערוך רפורמה ברכיבים הספציפיים של כוונה תחילה ושל הקנטור,¹⁰²⁶ לערוך רפורמה מקיפה בפרק עבירות ההמתה¹⁰²⁷ וכן בביקורת שהושמעה הן בפסיקה¹⁰²⁸ והן בספרות המשפטית¹⁰²⁹ על עבירת הרצח בחלופתה של המתת אדם בתוך כדי ביצוע עבירה אחרת או בהכנות לביצועה. כך, השופטות ביניש ופרוקצ'יה הביעו ביקורת על החלופה של רצח בתוך כדי ביצוע עבירה אחרת לפי סעיף 300(א)(3) וקראו לעריכת רפורמה מקיפה בעבירות ההמתה.¹⁰³⁰

כפי שנראה בהמשך, המבנה הלקוי של החקיקה דחף את בתי המשפט לפרשנות בעייתית של יסודות עבירת הרצח אגב הרחבת תחומה על חשבון עבירת ההריגה במידה שחורגת מלשון החוק ומתכליותיו.¹⁰³¹ בית המשפט עשה כן בהשראת המשפט האנגלי, בהופכו הלכה למעשה את עבירת הרצח מעבירה מוחמרת לעבירה בסיסית¹⁰³² ואת עבירת ההריגה מעבירה בסיסית לצורה הנתפסת כמוקלת. התוצאה אינה משביעת רצון, הן מכיוון שאין ביכולתו של בית המשפט לתקן את כל הטעון תיקון בחוק הישראלי, והן מכיוון שלנטילת משימות כאלה על ידי בית המשפט יש משמעות קשות מבחינת עקרון החוקיות וברמת (חוסר) היכולת ליצור הסדר כולל משביע רצון על בסיס שיפוט נקודתי במקרים ספציפיים.

להלן נמנה את הליקויים בחוק הישראלי עובר לתיקון מס' 137. לאחר מכן נבקש לסרטט כמה דגמים חלופיים של עבירות המתה אשר אינם לוקים בליקויים אלה. על מנת לבחור בדגם העדיף נידרש לליבון מטרות ההסדר ומטרות הענישה בתחום עבירות ההמתה. לאור דיון זה יוצעו קווים כלליים לסרטוט סימן עבירות ההמתה בחוק העונשין חדש, תוך התייחסות לתיקון מס' 137.

1026 לביקורת על הכוונה תחילה ועל הקנטור ראו גם שחר "כוונת המחוקק", לעיל ה"ש 16, בעמ' 204; ש"ז פלר "ה'הכנה' כיסוד הכוונה תחילה" הפרקליט כו 51 (1970); ש"ז פלר "עוד על ה'הכנה' כרכיב הכוונה תחילה" הפרקליט לג 578 (1981) (להלן: פלר "עוד על ה'הכנה'"); אהרן אנקר "רצח בכוונה תחילה" משפטים 478 (1976); נילי וילנסקי ומרדכי בס "לפרשנות היסודות של הכוונה תחילה: תגובה למאמרו של פרופ' אנקר" משפטים 499 (1975); אהרן אנקר "הערה נוספת לפרשנות היסודות של הכוונה תחילה" משפטים 512 (התשל"ו) (להלן: אנקר "הערה נוספת לכוונה תחילה"); קרמניצר "כוונה תחילה או כוונה רגילה", לעיל ה"ש 280, בעמ' 9; קרמניצר ולבנון "על היסוד של היעדר קינטור", לעיל ה"ש 277, בעמ' 547.

1027 דנ"פ ביטון, לעיל ה"ש 278.

1028 ראו עניין אבו זייד, לעיל ה"ש 688, פס' 39 ו-44 לפסק דינה של השופטת ביניש; עניין טמטאווי, לעיל ה"ש 690, פס' 49-50 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז; ע"פ 125/50 יעקובוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד 514 (1952).

1029 אנקר "רצח תוך ביצוע עבירה אחרת", לעיל ה"ש 16.

1030 עניין אבו זייד, לעיל ה"ש 688, בעמ' 410, 412.

1031 ראו בהמשך הדיון ב"כוונה תחילה", סימן 1 לפרק שישי.

1032 על כך שעבירת הרצח היא עבירת ההמתה הבסיסית במשפט האנגלי, ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 1006.

סימן ב: הליקויים בחוק עובר לתיקון מס' 137

1. עונש מאסר עולם כעונש חובה

העונש על עבירת הרצח אחרי שהוצאו ממנה המקרים המנויים בסעיף 300א הוא מאסר עולם כעונש חובה ללא שיקול דעת וגמישות. עונש זה החליף עונש מיתה מנדטורי שירשנו מן המנדט הבריטי ושרוטל בשנת 1954.¹⁰³³

זהו מצב דברים בעייתי. לא ניתן להגדיר נורמה שרק עונש אחד יתאים להתנהגויות שנופליות בתוכה. היסודות של הנורמה תופסים רק ממדים מוגבלים של המציאות, ואליהם יכולות להצטרף עוד איך-ספור וריאציות של נתונים העשויות להשפיע על המשקל האנטי-חברתי של ההתנהגות המוגדרת ועל אשמת העושה. על מנת שעונש יחיד יהיה תואם את העבירה נדרש שמידת האשמה הכרוכה בה תהיה שווה בכל הנסיבות, או שגם במקרים המגוונים במידה המעטה ביותר שבהם מתקיימות הנסיבות המקילות כבדות המשקל הגדול ביותר, תצדיק מידת האשמה את העונש. קשה לתאר מצב דברים כזה אלא אם כן קובעים בצד העבירה עונש קל ביותר, הרבה מתחת לרמת הענישה הראויה למקרי האמצע הטיפוסיים, ובכך בוודאי אין היגיון – לא גמולי ולא מניעתי. יש המציינים כי דווקא בעבירת הרצח קשת המקרים הנופלים בתוכה מבחינת חומרת האשמה שבהם היא רחבה במיוחד, כנראה בניגוד לתפיסה המקובלת של הפשע בעין הציבור.¹⁰³⁴ דברים דומים הביעו בית הלורדים האנגלי:

Murder, as every practitioner of the law knows, though often described as one of the utmost heinousness, is not in fact necessarily so, but consists in a whole bundle of offences of vastly differing degrees of culpability, ranging from brutal, cynical and repeated offences like the so called Moors murders to the almost venial, if objectively immoral, 'mercy killing' of a beloved partner.¹⁰³⁵

הוועדה האנגלית 1993 :

It is fundamentally wrong in principle that a judge should be required to pass upon the wife who has been maltreated for years by a brutal husband and eventually kills him, precisely the same sentence as that judge passes upon the ruthless shotgun robber who kill in cold blood. The two cases are extremes: but they help to illustrate that the area of culpability in murder cases is a very wide one.¹⁰³⁶

1033 חוק לתיקון דיני העונשין (ביטול עונש מוות על רצח), התשי"ד-1954, ס"ח 74.

1034 ראו גם Report of the Committee on the Penalty for Homicide (Chairman: Lord Lane of St ASHWORTH & MITCHELL ; Ippollitts), Prison Reform Trust (1993) לעיל ה"ש 847, בעמ' 5-7 ; Law ; Reform Commission, LCR 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.41 בעמ' 17, פס' 1.44-1.46 בעמ' 18.

1035 ראו עניין Howe, לעיל ה"ש 1013, בעמ' 433.

1036 ראו Report of the Committee on the Penalty for Homicide, לעיל ה"ש 1034, בעמ' 20.

וכן הוועדה האירית לרפורמה בעבירות ההמתה שדרשה את ביטולו של עונש מאסר עולם חובה:

All murders are not equally heinous. There is considerable moral variability in this category of homicide, just as there is in manslaughter. Some murderers display a level of appalling depravity or sadistic violence, but most murders occur in an emotional context.¹⁰³⁷

העובדה שהמחוקק נאלץ להוציא מתוך ההגדרה הנוקשה של רצח קטגוריות אחדות של מקרים (סעיף 300א) מלמדת על הקושי שבהגדרה נוקשה. קשה להאמין שהטכניקה הקזואיסטית שבעזרתה ניגש המחוקק להתמודד עם הבעיה פותרת אותה, בעיקר בשל היקפם המוגבל של המקרים שנופלים בגדר סעיף 300א. זאת ועוד, אין מדובר בסתם עונש חובה אלא בעונש חמור במיוחד, שונה איכותית ממאסר קצוב בחוסר הודאות שבו מבחינת האסיר, וזאת בשיטת משפט גישתה הכללית לענישה היא של הענקת גמישות מסוימת לבתי המשפט.¹⁰³⁸

הבעיה מוחרפת אצלנו משום שבהגדרה של עבירת הרצח נקט המחוקק את השיטה המפרטת הקזואיסטית ולא שיטה של נוסחה כללית ומופשטת, המאפשרת תיקון של הקשיחות בצד של קשיחות הסנקציה באמצעות הגמישות המובנית בנורמה עצמה. עמדה זו באה לידי ביטוי במשפט הגרמני שנוקט גם הוא הגדרה קזואיסטית להגדרת הרצח כאשר קיימים שלושה מודלים המאפשרים תיקון של הקשיחות: תיקון פוזיטיבי לרכיבי הרצח המחמירים, תיקון שלילי לרכיבי הרצח המחמירים ותיקון באמצעות העונש.¹⁰³⁹ ובפרקטיקה במשפט האנגלי, שבה במקרים של המתה שמקיימת את היסודות של עבירת הרצח אך אינה חמורה במיוחד תהיה ההרשעה בעבירת הריגה.¹⁰⁴⁰

כאשר מתנים את ההחמרה בהתקיימות רכיב אחד (נפשי, כמו כוונה תחילה או מטרה לאפשר ביצוע עבירה או להקילו או לחפות עליה, או נסיבתי, כמו בהמתת אב או בהמתה אגב ביצוע עבירה אחרת), אין מביאים בחשבון נתונים נוספים המשפיעים על הראויות לעונש ועל הנחיצות בעונש, ובהם מניעיו של העושה, מטרותיו (כאשר ההחמרה היא על יסוד רכיב נסיבתי), אופן ביצוע ההמתה, הסיטואציה הכוללת של ההמתה לרבות יחסי העושה עם הקורבן. קטן אפוא הסיכוי כי באמצעות הרכיב היחיד המובא בחשבון, ובהתעלמות מכל השאר, תתקבל תמונה שלמה והולמת של מידת חומרתו של המעשה. בייחוד אין מובאת בחשבון אפשרות התקיימותם במעשה – על נתוניו הקונקרטיים – של יסודות מפחיתי אשמה שהשפעתם מקזזת או מאיינת את השפעתו המחמירה של יסוד מחמיר. כמו כן גדל הסיכון כי התוצאה העונשית לא תהלום את מידת האשמה ואת הדרישה לעונש שהוא גם צודק וגם נחוץ, דרישה שניתן לעמוד בה רק בשקילה ובהבאה בחשבון של המעשה במלואו, ואולי גם של אישיות העושה, כפי שהיא מתבטאת במעשה.¹⁰⁴¹ ושוב, אילו היה ניתן לאפיין את הרצח באמצעות פירוט קזואיסטי שיכלול רק את המקרים החמורים ביותר (הראויים לעונש החמור ביותר) וכל המקרים

1037 ראו Law Reform Commission, LCR 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.44 בעמ' 18.
1038 חוק העונשין (תיקון מס' 113), התשע"ב-2012, ס"ח 2330, בעמ' 102 צמצם את שיקול הדעת המופלג שהיה לשופט בקביעת העונש.

1039 ראו להלן, הטקסט הצמוד לה"ש 1611-1614.

1040 ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 848.

1041 ראו גם Ashworth & Mitchell, לעיל ה"ש 847, בעמ' 9-10.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 209

האלה, היה המצב נסבל, אלא שדבר זה אינו אפשרי, ככל הנראה עקרונית, וכפי שהניסיון בתחום זה מיטיב ללמד. נדגים מן המשפט האנגלי והגרמני.

באנגליה נעשה שימוש בהגנת האחריות המופחתת במקרים שאינם של אחריות מופחתת כדי להימלט מעונש החובה,¹⁰⁴² כדוגמת המקרה של המתת המתעלל בידי קורבן ההתעללות שבו הפסיקה מפעילה את החלופה המוקלת של עושה בעל הפרעה נפשית חמורה או החלופה של קנטור מתמשך.¹⁰⁴³ עיון בפסיקה הגרמנית מעלה אפשרות חזקה שבתי המשפט נוקטים שם אסטרטגיות עקיפות שונות.¹⁰⁴⁴ יש לציין כי הדוגמה הגרמנית חשובה מזו האנגלית, שכן הגדרת הרצח שם צרה מאשר באנגליה, ובכל זאת ניכר כי מתעורר הצורך להימלט ממנה במקרים לא מעטים. אף כי ההגדרה של רצח במשפט הגרמני היא בכל זאת רחבה למדי, נטה היחס המספרי בין הרשעות ברצח לבין הרשעות בהריגה בשנים 1971–1974 בבירור לטובת הרשעות בהריגה. חשוב לא פחות שמתוך כלל מקרי הרצח, רק בפחות משליש הוטל מאסר עולם. אם מפחיתים את מקרי הניסיון לרצח, עדיין יוצא שעונש מאסר עולם הוטל רק בכל מקרה שני של רצח מושלם. הדרכים להגיע לתוצאה זו היו בעיקר שתיים: האפיק הראשון הוא היעדר בחינה קפדנית של העובדות המתייחסות להתקיימות רכיבים מחמירים, שלא לומר התעלמות מקיומם או התנאת "התקיימותם" בדרישות מהותיות והוכחות כבדות ביותר. האפיק החלופי הוא היזקקות לגורמים מקילים כגון אחריות מופחתת, כפי שנעשה בעניין פלוני שבו בית המשפט קבע כי תסמונת האישה המוכה יכולה לקיים הפרעה נפשית חמורה;¹⁰⁴⁵ הרחבה של הסיוע על חשבון הביצוע בצוותא בעיות ההבחנה ביניהם (מסייע הוא גם מי שביצע במו ידיו את העבירה עבור אחר)¹⁰⁴⁶ משום שהרשעה בסיוע מאפשרת הקלה בעונש; שימוש בהסדרים המיוחדים לעבריינים צעירים. האפיק השלישי הוא התחשבות בנסיבות מקילות מיוחדות, ללא פירוט שלהן, המאפשרות הימנעות מהטלת מאסר עולם ללא הסמכה חוקית מפורשת, ולדעת לא מעטים – בפרשנות יצירתית העוקרת את כוונת החוק והחורגת מן השורה.

שייכת לכאן כנראה גם הנטייה במשפט הגרמני לראות ברוב הרכיבים המחמירים אישיים מובהקים (täterbezogene Merkmale) על מנת למנוע מהם להקרין על משתתפים אחרים בעבירה. כך, במקרה שהנתון המחמיר קיים אצל המבצע העיקרי בלבד, השותף העקיף יישא באחריות פלילית לשותפות עקיפה להריגה¹⁰⁴⁷ או שותפות עקיפה לרצח, והעושה יזכה להקלה ניכרת.¹⁰⁴⁸ גם אם ניחס את המסלולים העוקפים הללו לדבקות קפדנית בעקרון האשמה או לאי-החשבה מספקת של ערך החיים, קשה להתעלם מהעדויות שהם מספקים לבעייתיות האינהרנטית של מפרט קזואיסטי, המתעוררת גם כשמגבשי המפרט באים ממסורת קודיפיקטורית מהוללת.

1042 Report of the Committee on the Penalty for Homicide, לעיל ה"ש 1034, בעמ' 33.
1043 R. v. Ahluwalia (Kiranjit), [1992] 4 All E.R. 889; R. v. Hobson, [1997] Crim. L. Rev. 759 and Commentary, [1998] 1 Cr. App. R. 31.
1044 Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 54–55.
1045 LG Offenburg StV 2003, 672.
1046 GÜNTHER JAKOBS, STRAFRECHT ALLGEMEINER, לעיל ה"ש 87 (Staschynskij); BGHSt 18, 87 (2 Aufl. 1993).
1047 Eser, לעיל ה"ש 406, §211, פס' 46.
1048 BGHSt 22, 377; BGH NStZ 1981, 299; BGH NStZ 1989, 19.

עד לשנת 2001, אז נחקק בישראל חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001¹⁰⁴⁹ היה העונש של מאסר עולם חובה בעייתי גם מהיבט נוסף. לא היה מנגנון מעוגן בחוק שהבטיח ששחרורו של האסיר (ברישיון) יישקל בשלב כלשהו, ומכאן שלא הייתה לאסיר תקווה מעוגנת נורמטיבית לשחרור (לבד מהתקווה הנסמכת על סמכות החנינה, שהיא סמכות של חסד).¹⁰⁵⁰ זו הכבדה יתרה על האסיר, היוצרת קושי ניכר גם בשיקומו, שהוא עניין חיוני – לו ולחברה. כמו כן ההבדלים בין האסירים בני-השיקום לעומת אסירים שאינם בני-שיקום מצדיקים בחינה פרטנית של השחרור ולא שלילה גורפת של אפשרות השחרור. תמונת הענישה בפועל על רצח הייתה שונה מן התמונה הנורמטיבית: בפועל היה נהוג שלאחר כמה שנים נשיא המדינה ממיר, במסגרת סמכות החנינה שלו, את עונש מאסר העולם בתקופת מאסר קצובה, לרוב של עשרים וארבע שנים.¹⁰⁵¹ בניכוי שליש על התנהגות טובה היו הנידונים על רצח משתחררים אחרי ריצוי ממשי של כשש-עשרה שנות מאסר.¹⁰⁵² יצא אפוא שהשיטה דיברה בשני קולות: הקול הרם של מאסר עולם חובה והקול השקט של עונש מאסר קצוב לאחר זמן. המרת עונש מאסר עולם בתקופת מאסר קצובה אינה מתאימה במהותה לסמכות החנינה שאופיה אינדיווידואלי מובהק. העתקתה מתחום המשפט לתחום החסד אינה הולמת מדינת חוק, ואין בה ערובה להבטחת השוויון בפני החוק.¹⁰⁵³ יתרה מזאת, סמכות החנינה מסורה בידי גוף פוליטי, וברור כי הגוף המתאים לקביעת עונש הולם לפי שיקולי גמול ומניעה כללית הוא גוף שיפוטי, שדרכי עבודתו מאופיינות באלמנטים של פומביות, הנמקה, מחויבות לעקיבות וכו'.¹⁰⁵⁴ כך, לפי פסיקתו של בית הדין האירופי לזכויות אדם בפרשת *Thynne*¹⁰⁵⁵ (אומנם בדבר מאסר עולם שאיננו עונש חובה),¹⁰⁵⁶ גוף

1049 ס"ח תשס"א, 410. פרק ה' לחוק, שכותרתו "קציבת עונש מאסר עולם והקלה בו", מסדיר מנגנון קציבה לפי בקשת האסיר (ס' 29 לחוק), הנשיא או שר המשפטים (ס' 30 לחוק). חוק שחרור על-תנאי ממאסר קובע את האפשרות לשחרר אסירים לפי שיקול דעתה של ועדת השחרורים ובכפוף לתנאים שזו תקבע. לפי ס' 9 לחוק, על הוועדה לשקול "את הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, את סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו בכלל". כמו כן קבועים בו התנאים לשחרור מטעמים רפואיים.

1050 החנינה היא מוסד חסד אם כי קיים רכיב של זכות והוא השוויון, במובן שלאדם יש זכות שיתנהגו כלפיו במקרים דומים בשוויון.

1051 הקציבה מעוררת את שאלת ההצדקה של עונש מאסר עולם חובה. עם זאת יש להכרזה על עונש זה ערך מרתיע מסוים, גם אם בפועל העונש נקצב ככלל בהמשך.

1052 הנשיא ויצמן הודיע תחילה כי לא יתמיד בנוהל זה, אולם לאחר המשבר שיצר, שהניב גם יוזמה לחקיקה, גם הוא לא נמנע מקציבת העונש על רצח.

1053 ראו גם אמירתו של Lord Bingham of Cornhill Newsam Memorial Lecture on "The Mandatory Life Sentence for Murder" 13 March 1998 "the sentence pronounced by the court is a formula, not a meaningless formula, but a formula which gives no real clue to the offender, to the victim, to the media or to the public at large, what-in practical terms – that is, in years to be served in prison – the sentence means. That is decided later" – *Law Reform Commission, LCR 87-2008* מ-צוטט נלקח מ-11978/86, [1990] ECHR 29, (1991) 13 EHRR 666, *Ashworth & Mitchell*, לעיל ה"ש 883, פס' 1.50 בעמ' 20.

1054 ראו גם *Ashworth & Mitchell*, לעיל ה"ש 847, בעמ' 7; *Ghanayim, Excused Necessity*, לעיל ה"ש 149.

1055 *Case of Thynne, Wilson and Gunnell, Vincent Berger Case Law of the European Court of Human Rights* 219 (1988-1990); *Thynne, Wilson and Gunnell v. the United Kingdom*, 11787/85, 11978/86, (1990) 13 EHRR 666, 12009/86, [1990] ECHR 29, (1991) 13 EHRR 666.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 211

שיפוטי שאיננו חלק מן הרשות המבצעת ואינו תלוי בה צריך להיות מופקד גם על שלילת חירות משיקולי סכנה שבעושה, והקובע לעניין מהותו של עונש איננו אופיו הפורמלי אלא טבעו האמיתי לפי כוונת המטיל אותו.¹⁰⁵⁷ בעניין *Stafford* הרחיב בית הדין האירופי לזכויות אדם את הלכת *Thynne* והחילה גם על מאסר עולם חובה. בהתבסס על סעיף 5(4) לאמנה האירופית לזכויות אדם נקבע כי לאסיר יש זכות שעם תום ריצוי העונש ההולם תיבחן חוקיות המשך מאסרו במאסר עולם חובה משיקולי מסוכנות, על ידי גוף בעל סמכות לשחררו ועל פי כללי משפט הוגן, לרבות שימוע. המשמעות היא שהגוף הבודק הוא ועדת שחרורים, כגוף שיפוטי, ולא מזכיר המדינה כגוף של הרשות המבצעת, כפי שהיה נהוג בפועל.¹⁰⁵⁸

אם כן, מה שעשוי להציל את עונש החובה היא הצלחה של המחוקק להגדיר בנורמה את כל המקרים הראויים להיכלל בה, בלא שייכלל בה מקרה שאינו ראוי לכך. כאמור, אין הדבר אפשרי, וגם המחוקק הישראלי לא חולל כאן נס.

2. היקף רחב מדי של עבירת הרצח לפני תיקון מס' 137

עבירת הרצח לפני קבלת תיקון מס' 137 התפרסה על פני מקרים שבהם מידת האשמה של העושה אינה הדרגה החמורה ביותר, ומכאן שסיווגם כרצח וגזירת מאסר עולם חובה בגינם הם בבחינת ענישה הפוגעת שלא כדין בכבוד האדם. יתרה מזאת, גם במוסד החנינה או מוסד השחרור המוקדם ממאסר אין כדי לרפא את הפגם, שכן מוסדות אלה מבטלים את הפגיעה הלא מוצדקת בחירותו של האדם, אך אין בהם כדי לרפא את הפגם הכרוך בעצם ההרשעה ברצח והטלת סטיגמה של רוצח.¹⁰⁵⁹ פגיעה נוספת נגרמת בכך שמקרים כאלה מושווים למקרים אמיתיים של רצח אף שאין הצדקה להשוואה זו, כלומר טיפול שווה במקרים שונים. למשל, החוק השווה המתה בכוונה תחילה להמתה מתוך קלות דעת בנסיבות מסוימות, דוגמת מתן מינון יתר של משככי כאבים לסבתו החולה מאוד של העושה מתוך מודעות לאפשרות שייגרם מוות, המלווה בתקווה שהמוות יימנע.¹⁰⁶⁰ והדוגמה מפ' *Lord Irvine of Lairg QC*, ולפיה –

A mercy killing is of a different moral order from a sadistic sex-based child murder...
I would suggest that it is beyond argument that murder embraces such a multitude of diverse sins that the single mandatory life sentence must be inappropriate.¹⁰⁶¹

¹⁰⁵⁶ לעניין זה ראו בעיקר עניין *Thynne, Wilson and Gunnell*, שם, פס' 50–54; Report of the Committee, לעיל ה"ש 1034, בעמ' 14.

¹⁰⁵⁷ ראו גם Law Reform Commission, LCR 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.53–1.54 בעמ' 21.

¹⁰⁵⁸ ראו *Stafford v. United Kingdom*, 2002-IV Eur. Ct. H.R. para. 87.

¹⁰⁵⁹ ראו *Ghanayim, Excused Necessity*, לעיל ה"ש 149.

¹⁰⁶⁰ ראו ס' 300(א)(1) הישן לחוק העונשין, המתייחס ל"גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו". כאשר הדבר נעשה בידי רופא במסגרת המקובל בטיפול רפואי, אפשר שהמעשה ייפול בגדר סייג לאחריות פלילית.

¹⁰⁶¹ הציטוט נלקח מ-Law Reform Commission, LCR 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.48 בעמ' 19.

מקרים נוספים שאינם ראויים ליפול בגדר רצח הם המתה בכוונה תחילה המונעת מרחמים על סבל נורא של הקורבן המבקש את מותו; המתה במצב של ייאוש, כגון אם הנוטלת את חיי ילדה, כאשר היא מבקשת להמית בראש ובראשונה את עצמה, על מנת לגאול אותו מחיים אומללים, וניסיונה להמית את עצמה נכשל; חלק ממקרי ההמתה מתוך קנטור סובייקטיבי שאינם עומדים במבחן האובייקטיבי של קנטור; המתה בתוך כדי ביצוע עבירה אחרת או הכנות לביצועה, לפי סעיף 300(א)(4) עובר לתיקון מס' 137, שכן הסעיף מסתפק בזיקה זמנית בלבד בין ההמתה לבין ביצוע העבירה האחרת, שאין בה כדי לשוות בהכרח להמתה אופי חמור במיוחד הן מבחינת האנטי-חברתיות שבה והן מבחינת האשמה. זאת, בייחוד כאשר העבירה האחרת יכולה להיות עבירה קלה, כגון אי-דיווח לרשויות המס, החזקת טובין האסורים בהחזקה וכד'. אומנם ייתכנו מקרים שבהם קיימת הצדקה להחמרה בענישת עבירות מסוימות שבמהלכן נגרמת תוצאה קטלנית, ולא דווקא מתוך מחשבה פלילית, אך לא במסגרת עבירת הרצח אלא בעבירות היוצרות סכנה טיפוסית לחיים, כגון גרימת חבלה חמורה,¹⁰⁶² או העבירה המיוחדת שהיא הרכבה של חבלה או חבלה חמורה במחשבה פלילית עם גרימת מוות ברשלנות כמקובל במשפט הקונטיננטלי.¹⁰⁶³ דומה כי סעיף 300(א)(4) עובר לתיקון מס' 137 נקבע על מנת להתגבר על קשיי הוכחה שנבעו משימוש בחלופה של המתה המיועדת לקדם ביצוע עבירה.¹⁰⁶⁴ כמן כן לא כל מקרה של המתה שתכליתה למנוע את גילוי העבירה או ענישת המשתתפים בה מצדיק את ההחמרה לרצח, כגון במקרה שבו העבירה המקורית נעשית בשל התגרות חמורה, ובאותו מצב של התרגשות ניכרת נעשית גם ההמתה.

3. היעדר התייחסות למקרים מיוחדים שאינם ראויים ליפול בגדר עבירת הרצח

חסרה בחוק התייחסות למקרה המיוחד של המתת אדם המבקש את נפשו למות על רקע של סבל קשה שאין ממנו מילוט בגלל מחלה חשוכת מרפא. נוסף על כך, עד לחקיקת סעיף 300א לחוק העונשין סבל החוק מאי-התייחסות מקילה למקרי המתה בעקבות קונפליקט מתמשך, כגון המקרה של המתת הורה, בעל או בן מתעלל בידי קורבן ההתעללות או קרוביו, שקיימו את יסודות עבירת הרצח המנויים בסעיף 300(א)(1) ו-300(א)(2) הישן לחוק העונשין. אומנם המתת הורה יכולה במקרים רבים לבטא עמדה אנטי-חברתית מגונה במיוחד המלווה באשמה חמורה, אולם ייתכנו מקרים שבהם המצב המשפטי שונה, למשל כאשר המומת הוא עריץ שבני המשפחה הם קורבנות תמידיים של מעשי ההתעללות שלו. התיקון לסעיף 300א בחוק העונשין משנת תשנ"ה איפשר הקלה בעונש במקרה כזה.¹⁰⁶⁵ התיקון לחוק הוא עדות לכישלון ההגדרה הממצה והמחייבת מבחינת התוצאה, אולם כפי שראינו, ספק אם דרכו של התיקון צלחה. נוסף על כך, כאמור, ייתכנו מקרים אחדים של קנטור סובייקטיבי שאין בו גם קנטור אובייקטיבי ושאין ראויים ליפול בגדר רצח משום שמעשה ההמתה לא נעשה בדם קר ולאחר שקילה.

¹⁰⁶² ס' 333 לחוק העונשין הישראלי; ס' 122 ו-129 לחוק השווייצרי.

¹⁰⁶³ כגון ס' 227 לחוק הגרמני, ס' 86 לחוק האוסטרי.

¹⁰⁶⁴ ראו גם הסחיטה המוחמרת אצלנו המחמירה בדין הסוחט הן כאשר נעשה המעשה או המחדל מפני האיום או הטלת האימה שבסחיטה או במהלכם, בס' 428 לחוק העונשין (אולם אין זה טעם מצדיק).

¹⁰⁶⁵ ס' 300א(ג) לחוק העונשין.

4. היעדר התייחסות למקרים מיוחדים הראויים ליפול בגדרי עבירת הרצח

מחוץ לגדר עבירת הרצח נשארים מקרים שהיו ראויים להיכלל בה, כגון המתת אדם מתוך תאוות המתה לשמה, המתה לשם סיפוק יצר המין, המתה בהתאכזרות מיוחדת או בתוך כדי גרימת סיכון לחיי אנשים נוספים, המתת אדם מתוך מוטיבציה גזענית, המתה טרוריסטית, המתה שמבצע ארגון פשע וכן המתה המופקדים על אכיפת החוק בקשר לתפקידם – והכול כאשר העושה אינו פועל בכוונה תחילה. חומרת האנטי-חברתיות והאשמה שבהמתות כאלו רבות מאוד עד כי הן מצדיקות ואף מחייבות סיווגן לרצח. לטענתנו, ההבחנה בין מקרים אלו לבין רצח בכוונה תחילה היא בבחינת הקלה לא מוצדקת עם הראשונים, ואף פגיעה בשוויון, שכן מדובר במקרים שאין להבחין ביניהם מבחינת חומרתם.¹⁰⁶⁶

5. תרומת המבנה בדין הישן לפיחות בחשיבות הערך של חיי אדם

המבחן האמיתי (או לפחות מבחן בעל כוח הסבר רב ביותר) ליחסו של החוק לערך של חיי אדם אינו דווקא הטיפול במקרי ההמתה החמורים אלא דווקא טיפולו במקרים החמורים ה"רגילים" הנעשים מתוך עמדה נפשית מגונה. קיים מתח בין נקודת מוצא עונשית, היוצאת מן העונש החמור ביותר ומתמקדת בצד העבירה באפיונו כמקרה שיצדיק את הטלת העונש החמור ביותר, לבין הבלטת החשיבות של הערך המוגן של חיי אדם שממקדת את המבט במקרים הרגילים מבחינת חומרתם. מבחינה זו ניתן להצדיק את העונש החמור ביותר למי שמחולל במודע (ולפחות מתוך אדישות) את הרע האולטימטיבי והאבסולוטי של קיפוח נפש, כאשר חומרת הפשע הזה כשלעצמו מחייבת הכללתו בקטגוריה שבצידה העונש החמור ביותר. אם אין נוהגים כך, מפחיתים את הערך של חיי אדם. ליקוי בסיסי במבנה הישן היה אפוא תרומתו לפיחות בחשיבות הערך המוגן בשל ההתמקדות במקרים החמורים ביותר. עיסוק יתר במקרים החמורים ביותר והדגשתם המופרזת עלולים להעביר מסר של פיחות בחשיבותם של חיי אדם, כביכול עיקר החומרה והחשיבות אינו בהמתת אדם כשלעצמה אלא באותם רכיבים שמעניקים לה חומרה מיוחדת, ואילו הגישה הראויה היא שהמתה מתוך עמדה נפשית מגונה (הנעשית מתוך כוונה או אדישות) של אדם, שלא בנסיבות מקילות, חמורה דייה כדי שייקרא שמה "רצח", ויוצמד לה העונש המיוחד, החריג בחומרתו, של מאסר עולם.

אפשר שהפסיקה תרמה לכך באופן פרדוקסלי במאמציה להרחיב את עבירת הרצח על חשבון ההריגה, עד שהעבירה אל הרצח כמעט את כל המקרים של המתה בכוונה, כאילו אין חומרה ניכרת מאוד בהמתת אדם שאיננה בקטגוריה החמורה ביותר.¹⁰⁶⁷ מכאן חשיבותה המיוחדת של עבירת ההריגה. כישלוננו של החוק כאן הוא כפול: בהיקף הרחב של עבירת ההריגה, שנכללה בה בעבר גם המתה שהיא תוצאה אקראית של חבלת גוף מתוך קלות דעת;¹⁰⁶⁸ וחשוב לא פחות, בויתור המוחלט

¹⁰⁶⁶ ראו גם Alan C. Michaels, *Defining Unintended Murder*, 85 COLUM. L. REV. 786 (1985).

¹⁰⁶⁷ ראו לעיל, הטקסט הצמוד לה"ש 1033–1034.

¹⁰⁶⁸ ראו ההלכה שנקבעה בע"פ 1/52 דויטש נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ח(1) 456, 471 (1954): "אין זה הכרחי שהנאשם יחזה מראש את התוצאה הקטלנית דווקא, כי אם מספיק הדבר... שכזה כאפשרות קרובה כי התנהגותו תגרום נזק ממשי לגופו של אדם. במלים אחרות, די אם הנאשם היה ער לכך שסכנה לחיים או לבריאות נשקפת ממעשהו". בית המשפט חזר על ההלכה במקרים שונים. ראו למשל ד"נ 7/69

על הכוונתו והדרכתו של המחוקק את הענישה. לכאורה, היה ניתן לראות בחומרתו של העונש המרבי על עבירת ההריגה – עשרים שנות מאסר – איתות חזק מאוד לחומרתה המיוחדת, אולם עיון בהוראות החוק מעלה כי עונש זה הוצמד לעבירות לא מעטות, לאו דווקא החמורות ביותר,¹⁰⁶⁹ עובדה המפחיתה מחשיבותו של העונש המרבי כביטוי מודגש של חומרת העבירה.

התהווה מצב דברים מעניין: אף שנורמטיבית ההריגה הייתה הצורה הבסיסית, היא אינה נתפסה ככזו בעין הציבורית אלא כצורה קלה. ההסברים לכך עשויים להיות שונים, וניתן כמובן אפשרות של הצטברות שלהם: תשומת הלב התקשורתית, וממילא הציבורית, מתמקדת במקרי הרצח, ועקב כך הופך הרצח דווקא לצורה הרגילה של המתת אדם.¹⁰⁷⁰ וכן העובדה שהמחוקק יצר דרגה אחת בלבד של רצח ולא הבחין בין רצח רגיל לרצח בנסיבות מחמירות.

מעניין במיוחד התפקיד שמילאה הפסיקה בנושא זה, שהוא בעל אופי כפול של מושפע ומשפיע: באמצעות הפרשנות המרחיבה שניתנה לכוונה תחילה הרחיבה הפסיקה את עבירת הרצח¹⁰⁷¹ ובכך תרמה לזיהוי ההריגה עם המקרה הקל של המתה. מאידך גיסא אפשר שבית המשפט ביטא בכך אותה תחושה שלפיה המקרה הרגיל של המתת אדם (שלא בקלות דעת) הוא רצח לאו דווקא כנהייה מודעת אחרי תודעת הציבור אלא כביטוי של שותפות לאותה תחושה. ראוי לציין כי התפתחות דומה ניתן למצוא בגישתה של הפסיקה הגרמנית ל"מניעים שפלים" כיסוד של עבירת הרצח, וכוונתנו לנטיית הפסיקה שם לייחס מניעים שפלים לנאשם בכל מצב שבו הרקע להתנהגותו לא היה ניתן להבנה אנושית;¹⁰⁷² ללמדנו על הגישה הרווחת, שלפיה רצח הוא כל המתה באדישות או בכוונה שלא נבעה מרקע כאמור.¹⁰⁷³

אליאס נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(1) 561 (1969); ע"פ 149/83 רוט נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(3) 824 (1983).

¹⁰⁶⁹ ס' 259 לחוק העונשין קובע: "המבריח או מנסה להבריח אדם ממשמורת חוקית, דינו – (1) אם המוכרח הואשם או הורשע בעבירה שענשה מוות או מאסר עולם – מאסר עשרים שנים". ס' 373 קובע: "המוציא, במעשה או בפיתוי, קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים או אדם שאינו שפוי בדעתו, ממשמורתו של אפוטרופס על פי דין – בלי הסכמת האפוטרופוס, דינו – מאסר עשרים שנים". ס' 448 קובע מאסר של עשרים שנה למי ש"משלח אש במזיד בדבר לא לו... במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה".

¹⁰⁷⁰ ראו קרמניצר "כוונה תחילה או כוונה רגילה", לעיל ה"ש 280, בעמ' 9.

¹⁰⁷¹ יסוד ההכנה פורש כיסוד פיזי המתמלא "על ידי אותן פעולות של הנאשם, המהוות חלק ממערכת פעולות הקטילה גופן; כגון טלטול כלי הפצירה מטרים אחדים למיתתו של הקרבן והנחתת מכות קשות ורבות בראשו, באמצעות הכלי הזה" – ראו ע"פ 69/54 **מדורסאן נ' היועץ המשפטי לממשלה**, פ"ד יח 930, 933 (1954); דקירת הקורבן שמוחנה דקירות בחלקים פגיעים שונים של גופו – ראו ע"פ 186/57 **אליהו נ' היועץ המשפטי לממשלה**, פ"ד ח יב 236, 245 (1958); ע"פ 889/78 **מוגריבי נ' מדינת ישראל**, פ"ד לד(1) 576 (1979); פרשת בנו, לעיל ה"ש 986; ע"פ 655/78 **שמידמן נ' מדינת ישראל**, פ"ד לד(1) 63 (1979); ע"פ 553/77 **תומא נ' מדינת ישראל**, פ"ד לב(3) 141 (1978); וראו ביקורתו של ש"ז פלר פלר "עוד על ה'הכנה'", לעיל ה"ש 1026, בעמ' 578. המבחן לקיומו של קנטור פורש כמבחן אובייקטיבי – ראו ע"פ 46/54 **היועץ המשפטי לממשלה נ' סגל**, פ"ד ט 393 (1955).

¹⁰⁷² ראו Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 44.

¹⁰⁷³ מנגד, אין לשכוח קיומה של המגמה השיפוטית בגרמניה, שעליה עמדנו לעיל, לצמצם את היקף הרצח – כמשיכה של הקוטב השני – כפועל יוצא של כישלון האפיון הקזואיסטי וכביטוי לרצון להימנע מלהטיל מאסר עולם כשהוא יותר מן המגיע.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 215

אפשר שבשנים האחרונות התחולל שינוי מסוים במגמה שניתן לאתר בה מקרים שבהם מאשימים ומרשיעים בהריגה במקרים אשר על פי הפסיקה שנהגה, הם קרובים מאוד לרצח, ולהרשעה מתלווים עונשים חמורים מאוד, הקרובים לעונש המרבי של עשרים שנות מאסר.¹⁰⁷⁴ שינוי כזה עשוי היה להיות תיקון מסוים למצב הדברים שהתהווה, וזאת במיקוד תשומת הלב במקרים ה"בסיסיים", המטופלים בחומרה רבה במסגרת עבירת ההריגה. עם זאת לא יכול להיות בכך משום תיקון מושלם, בשל הליקויים שמקורם במבנה החקיקתי – בעיקר כריכתן יחד של המתה בכוונה והמתה מתוך קלות דעת במסגרת עבירת ההריגה והיעדר ענישה הולמת מיוחדת להמתה מתוך כוונה או אדישות.

6. הענקת חשיבות מוגזמת לשאלת השיבוץ: רצח או הריגה

בשל המבנה החקיקתי האמור ובשל המגמה שניכרת בפסיקה עד לתיקון מס' 137 נוצר ניגוד חריף, בלתי נסבל, בין חומרתה המופרזת של עבירת הרצח לבין קלותה הבלתי נסבלת של ההריגה. ניגוד זה

¹⁰⁷⁴ ראו למשל ת"פ (ת"א) 30333/06 **מדינת ישראל נ' יוסי חזן** (הכרעת דין מיום 27.6.2007, גזר דין מיום 10.9.2007), שם הואשם והורשע בהריגה הנאשם, אשר הכה עם אחרים את הקורבן למוות בעת קטטה במועדון, ונגזרו עליו 17 שנות מאסר, מתוכן 15 לריצוי בפועל. בית המשפט הדגיש את "האכזריות, הרשע והרוע שבהתנהגות הנאשם" (פסקה אחרונה לגזר הדין). ראו גם ע"פ 1456/01 **חדד נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 22.10.2001), שם הורשע בהריגה נאשם שהמית את קורבנו בדקירה על רקע הערה של מה בכך, ונגזרו עליו 20 שנות מאסר בפועל. בית המשפט ציין בפס' 3 לפסק הדין: "אכן, העונש שנגזר על המערער הוא העונש המרבי הקבוע לעבירה בחוק. אולם, יש לזכור, כי במדרג המעשים הגורמים למוות של אדם, עומד מעשהו של המערער, כפי שתואר בראש הדברים, בדרגה החמורה ביותר, זו המתקרבת לרצח, ורק כפשע היה בין המערער לבין הרשעתו ברצח. על כך אמר בית המשפט המחוזי: 'שלושה הם יסודות עבירת הרצח: העדר קינטור, הכנה והחלטה להמית... רק לגבי יסוד ההחלטה להמית התעורר בלבנו ספק אם אמנם חפץ הנאשם בתוצאה הקטלנית של רצח המנוח, ובשל כך הרשענו אותו בהריגה ולא ברצח'. ובמקום אחר אמר: '...אנו סבורים שלא יכול להיות מקרה יותר קרוב לרצח מהמקרה שבפנינו, ולכן אין בלבנו כל היסוס, שיש להטיל על הנאשם את העונש המרבי הקבוע בחוק על עבירת ההריגה'. חיי אדם הם ערך מקודש בחברתנו. המעשה שעשה המערער הוא ביטוי קיצוני של זלזול בערך זה. עליו, ועל עוברי עבירה כמותו, לשאת בעונש המרבי הקבוע בחוק; אלא אם כן נמצא צד זכות המצדיק הקלה בעונש. כזה לא נמצא למערער". ראו עוד ע"פ 6144/02 **ואנונו נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 17.1.2005) וע"פ 6795/05 **ואואנינו נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 29.1.2007) (זיכוי מרצח והרשעה בהריגה עם עונש של 19 שנות מאסר, מתוכן 18 לריצוי בפועל, של מי שהמית במהלך קרב סכינים מתוכנן מראש). ראו גם ע"פ 70/04 **פוריאדין נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 19.1.2006), שבו אישר בית המשפט העליון הן את הרשעתו בהריגה של המערער, אשר הכה באשתו למוות, והן את העונש של 19 שנות מאסר, מהן 17 לריצוי בפועל. השופט עדיאל ציין בפס' 20 לפסק דינו כי "במקרה שלפנינו... מעשיו של המערער התאפיינו באכזריות רבה שעלתה כדי התעללות". יש לציין כי השופט חשין הביע ספק בשאלה אם תיוג המקרה כהריגה הוא הולם, וסבר שיש מקום לתיקון חקיקתי שיביא מקרים דוגמתו לעבירת רצח מדרגה שנייה; בפס' 4 לפסק דין חדר בית המשפט אף מצא לנכון להטעים במיוחד את חומרתה הרבה של עבירת ההריגה ולקבוע מדיניות ענישה מחמירה בעניינה: "העבירה של שפיכות דמים – שהיא משבע מצוות בני נח ומשלושת העבירות שעליהן 'ייהרג ולא יעבור' – היתה כמעט לדבר יום ביומו. אך למותר להרבות בדברים על חומרתה של עבירה זאת... כאשר זה המצב אין אנו פטורים עוד מלהתוות קיום לרמת הענישה הראויה שבגדרם יש לנקוט בגישה המחמירה, לאמור בגישה הרואה בעונש המרבי את נקודת המוצא; שממנו מפחיתים לפי נסיבות המקרה, נסיבותיו האישיות של העבריין, תדירותה או נדירותה של העבירה, הרתעת עבריינים בכוח ועצמת הסלידה ושאת הנפש של החברה".

מזכיר את הניגוד שממנו סבלה ההבחנה בעבר: בין עונש מוות לענישה אחרת (אחרי תקופה שבה ההבחנה הייתה בין סוגים שונים של הוצאה להורג)¹⁰⁷⁵ ובהתפתחות ההיסטורית באנגליה – בין אפשרות לחנינה לבין היעדרה.¹⁰⁷⁶ ניגוד זה מעניק חשיבות דרמטית, מוגזמת, לשאלת השיבוך – רצח או הריגה.

נוסף על כך, ככל שנפקות ההבחנה חשובה יותר, בעלת השפעה גדולה יותר, כן גדל הנטל הרובץ על המחוקק לערוך הבחנה ראויה, וגדל כישלונו כאשר אין הוא עומד בכך. החיבור בין הגדרה קזואליסטית קשיחה לבין עונש חובה של מאסר עולם הוא אפוא בעייתי במיוחד. מתיאור זה של הבעיה עולות כבר במבט ראשון האפשרויות השונות לסילוקה או לריכוכה, שהן כולן בכיוון של הגמשה. יתרון כללי של פתרון גמיש שהוא מאפשר להגיע לתוצאה ראויה בדרך הישירה והישרה ולהימנע מדרכי המעקף והמילוט, לרבות עיוות הנתונים העובדתיים וסילוף החוק, שמאפיינים הסדרים שהם קשיחים מדי. את ההגמשה ניתן להשיג בדרכים שונות: כאשר יש גמישות בצד הסנקציה ניתן לנקוט יתר דיוק בהגדרה ובאפיון הנורמה, וכאשר הנורמה מאופיינת בגמישות, ניתן לסבול קשיחות בצד הסנקציה.

7. איזון לא ראוי בין תכליות שונות של ההסדר

מגמת החוק עובר לתיקון מס' 137 הייתה להעניק עדיפות מכרעת לשיקולי מניעה כללית וגמול ולהשיג ביטחון וודאות משפטיים, ולו גם על חשבון צדק ליחיד (שיקולים המתמקדים בעושה ובהשפעת העונש עליו), היא בעייתית. היא מעניקה משקל מכריע ובלבדי למגמה הראשונה (הצירוף של קזואליסטיקה נוקשה עם עונש חובה נועד בעיקר להשיג ביטחון, ודאות ואחידות) ומתנכרת לחלוטין לשיקול האחר. גם הפסיקה, שהרחיבה מאוד את מושג הכוונה תחילה, החרתה אחר אותה מגמה ושילמה מחירים לא מבוטלים.¹⁰⁷⁷ קשה לומר שהפסיקה, בפרשה את המושג "כוונה תחילה", פירשה אותו לפי משמעותו הרגילה או פירוש שיהלום את הגדרתו. פרשנות כזו יוצרת לכאורה אי־ודאות משפטית בגלל הפער שהקהילה המשפטית מתקשה לקבל בין לשון החוק לבין הפרשנות הניתנת לו, ועד שהיא מתייצבת ברמה של הלכה שלא ניתן עוד לערערה, נגרמת דווקא אי־יציבות משפטית.¹⁰⁷⁸ לאחר שהתגבשה הלכה פסוקה בעניין זה, הפך השיקול של יציבות משפטית לשיקול מרכזי המונע שינוי בהלכה הפסוקה גם כאשר שינוי זה מתבקש – אפילו לדעת השופטים עצמם¹⁰⁷⁹ – כדי לעשות

¹⁰⁷⁵ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 771 ואילך.

¹⁰⁷⁶ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 748 ואילך.

¹⁰⁷⁷ ראו לעיל, בסימן 6 – הטקסט הצמוד לה"ש 1069–1076 – העוסק בפיחות ערך החיים.

¹⁰⁷⁸ "כלל גדול הוא בדיני העונשין: אין עונשין מן הדין" (סנהדרין נ"ד, ע"א ועוד)... אלא מן החוק הכתוב והחקוק בלבד" (ראו ע"פ 205/73 סטיבן איבן רוס נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(2) 356 (1973)). לפיכך ניתן לראות בפרשנות היוצרת של בית המשפט משום סטייה מעקרון החוקיות, במיוחד כשהיא כרוכה בהרחבת היקף העבירה כדי שתכלול מעשים רבים יותר בגדריה.

¹⁰⁷⁹ כמה שופטים הביעו אי־נחת מן ההלכה המרחיבה בעניין יסוד ההכנה – ראו ש"ז פלר "הכנה" כמידה של 'כוונה תחילה' – גלגול איטי אך הכרחי "משפטים" כו 379, 391–395 (1996) (להלן: פלר "הכנה" כמידה של 'כוונה תחילה') וראו פסק דינו של הנשיא ברק בדנ"פ ביטון, לעיל ה"ש 278.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 217

צדק למעשה ולעושה. הוויתור על עשיית צדק כאמור משקף ככל הנראה גם מתן עדיפות מכרעת לשיקולי מניעה כללית על חשבון השיקול של אשמה.

סימן ג: שיקולים כלליים להתמודדות עם הבעיה וקווים מנחים לרפורמה, תוך התייחסות לתיקון מס' 137

הבעיה מרתקת וסבוכה, היא מחייבת התייחסות לשאלות כלליות ועקרוניות של המשפט הפלילי ושל תורת המשפט, ובהן מטרות הענישה ושיקולי הענישה הכלליים, השיקולים להחמרה ולהקלה (אנטי-חברתיות, אשמה או סכנה), היחס בין נורמה לבין העונש שבצידה (גם מכיוון ההשפעה של העונש על הנורמה), היחס בין נורמה לשיקול דעת, הכללה וקזואליסטיקה, המתח בין הבלטת חשיבות הערך של חיי אדם לבין עקרון האשמה (או חיי אדם מול כבוד האדם, שעקרון האשמה נגזר ממנו), המתח בין שיקולים של ודאות החוק, מסוימותו ומוגדרותו (הביטחון המשפטי, אחדות בהפעלה ובתוצאות) לבין צדק במקרה האינדיווידואלי, בין נקודת המבט הקורבנית לבין נקודת המבט העבריינית (למשל בהתאכזרות – האם לדרוש עמדה נפשית מיוחדת של המתאכזר? האם להתחשב בסיבת הזדקקותו לעיניים? או שמא להסתפק בענותו של הקורבן ובסבל הפיזי או הנפשי שנגרם לו, שהעושה מודע להם) והתרגום של מהות לטכניקה חקיקתית.

נקודת המוצא צריכה לכלול התייחסות לליקויי המצב הקיים לשם הפקת לקחים. המסקנות הטנטטיביות הן, ראשית, עונש קבוע (fixed) תובע דרישות שלא ניתן לעמוד בהן בתחום ההגדרה, ויש להימנע ממנו. יש להכיר בגבולות היכולת האנושית ולהימנע מיומרה שאין לה כיסוי. פירוט מחמיר ומחייב על טוהרת הקזואליסטיקה הוא בעייתי ביותר, ולכן יש לנקוט אמצעים להגמשת הקזואליסטיקה (אחת מהן היא הדרך של נסיבה מחמירה בדרך כלל – *In der Regal*). נוסף על כך, יש לשקול את האפשרות, שכבר עמד עליה פון ליסט,¹⁰⁸⁰ ליצור תחום חפיפה במסגרת העונשית בין צורה בסיסית לבין צורה מוחמרת כביטוי של חוסר היכולת ליצור חיתוכים מושלמים בתחום ההגדרתי בשל האפשרויות האין-סופיות של המציאות. לקח שני הוא שיש ליתן הדעת לשאלת המסר הנובע מן ההסדר החוקי לעניין חשיבותו של הערך חיי אדם, כמובן מבלי לשכוח שיקולים מרכזיים אחרים, שהחשוב שבהם הוא ענישה תואמת-אשמה – עיקרון אשר אין לסטות ממנו. בשל כך מתחייב למקד את תשומת הלב במקרה החמור הרגיל של המתת אדם מתוך כוונה או אדישות. יש לתת מענה למקרים שבהם רמת האשמה חמורה במיוחד ולמקרים שבהם יש פחות רב בדרגת האשמה.

1. דגמים אפשריים

הדגמים המקובלים בעולם הם שלושה: דגם של עבירה אחת, דגם של שתי עבירות ודגם של שלוש עבירות.

1080 ראו Liszt, לעיל ה"ש 10, בעמ' 26–27.

א. דגם של עבירה אחת

לפי דגם זה, המתת אדם במחשבה פלילית מוגדרת בעבירה פלילית אחת, וקיים ויתור על הבחנות בין סוגים שונים של המתת אדם מתוך מחשבה פלילית; אין עוד עבירות של המתה מוקלת בנסיבות מקילות או רצח כהמתה מוחמרת בנסיבות מחמירות. דגם זה מקובל בדנמרק,¹⁰⁸¹ באיסלנד, בפרס, ובחלק מהספרות המשפטית ועל שופטים.¹⁰⁸²

ב. דגם של שלוש עבירות

האפשרות (הקיצונית) ההפוכה היא דגם תלת-שכבתי: עבירה בסיסית של המתה רגילה, שממנה מסתעפות כלפי מעלה צורה מוחמרת וכלפי מטה צורה מוקלת (כמו גרמניה,¹⁰⁸³ שווייץ,¹⁰⁸⁴ פורטוגל,¹⁰⁸⁵ צ'כיה,¹⁰⁸⁶ ארגנטינה,¹⁰⁸⁷ רוסיה,¹⁰⁸⁸ פינלנד,¹⁰⁸⁹ רומניה, מדינות בארצות הברית שמבחינות בין שתי דרגות של רצח¹⁰⁹⁰ והצעת חוק אנגלית¹⁰⁹¹).

ג. דגם של שתי עבירות

האפשרות השלישית היא אפשרות ביניים: דגם דו-שכבתי, וקיימים בעניינו שני מודלים: לפי המודל הראשון מבחינים בין עבירת המתה שחובקת את המקרים הרגילים של המתת אדם במחשבה פלילית ואת המקרים החמורים במיוחד של המתת אדם לבין המתה מוקלת שחובקת את המקרים הקלים של

¹⁰⁸¹ מודל דני זה מוסבר מבחינה היסטורית. חוק העונשין הדני משנת 1866 הבחין בין רצח לבין הריגה באמצעות הרכיב של כוונה תחילה, אולם על רכיב הכוונה תחילה נמתחה ביקורת חריפה, ונאמר כי אינו מתאים לכך, בדומה למשפט הגרמני. בשל הביקורת והקשיים באימוץ מודל מבחין שאין עוררין עליו החליט המחוקק לאמץ מודל של עבירה אחת, ובכך להעניק לבתי המשפט שיקול דעת רחב מאוד, כאשר בתי המשפט הדנים זוכים לאמון רב מאוד בקרב הציבור. ראו REIZEL, לעיל ה"ש 636, בעמ' 26–27.

¹⁰⁸² ראו ARVANITIS, לעיל ה"ש 1, בעמ' 117; Liszt, לעיל ה"ש 10, בעמ' 100; Hans-Georg Koch, *Gesetz- und Vertragsentwürfe in juristischen Übungsarbeiten*, JuS 1972, 457; LORR, [1987] 2 WLR 586, 581; Hailham, ב-88, בעמ' 98; LOUIS BLOM-COOPER & TERENCE MORRIS, WITH MALICE AFORETHOUGHT: A STUDY OF THE CRIME AND PUNISHMENT FOR HOMICIDE (2004).

¹⁰⁸³ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 660–652.

¹⁰⁸⁴ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 679–667.

¹⁰⁸⁵ ס' 131 ואילך לחוק הפלילי ההפורטוגלי; ראו Peter Hünerfeld, *Landesbericht Portugal*, in STRUKTURVERGLEICH STRAFRECHTLICHER VERANTWORTLICHKEIT UND SANKTIONIERUNG IN EUROPA 541, 550 (Eser/Perron Hrsg., 2015).

¹⁰⁸⁶ החוק הצ'כי נוקט כאן טקטיקה של ס' 140, שכותרתו רצח. סעיף קטן 1 מגדיר את ההמתה במחשבה פלילית בתור עבירה בסיסית, ואילו סעיפים קטנים 2 ו-3 מגדירים את ההמתה המוחמרת שהיא המתה בכוונה תחילה ונסיבות מחמירות אחרות. ס' 141 מגדיר את ההמתה בנסיבות מקילות, כגון המתה עקב אפקט כאשר העונש נע בין שלוש לעשר שנים.

¹⁰⁸⁷ ראו ס' 79–81 לחוק הארגנטיני.

¹⁰⁸⁸ ראו ס' 105–108 לחוק הרוסי.

¹⁰⁸⁹ ראו פרק 21 ס' 1–3 לחוק הפיני.

¹⁰⁹⁰ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 940 ואילך.

¹⁰⁹¹ ראו Law Commission Consulting Paper No. 177, לעיל ה"ש 21, בעמ' 27.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 219

המתת אדם; מודל זה קיים במדינות אלה: אוסטרליה,¹⁰⁹² שוודיה,¹⁰⁹³ יוון, בלגיה, לוקסמבורג, מדינות בארצות הברית שאינן מבחינות בין דרגות הרצח,¹⁰⁹⁴ אנגליה ואירלנד.^{1095, 1096} לפי המודל השני, שמקובל בצרפת,¹⁰⁹⁷ באיטליה,¹⁰⁹⁸ בנורווגיה¹⁰⁹⁹ ובוועדה האנגלית,¹¹⁰⁰ מבחינים בין המתה שחובקת את המקרים הרגילים של המתת אדם במחשבה פלילית ואת המקרים של המתה מוקלת לבין המתת אדם מוחמרת המכונה רצח.

2. המודל הרצוי ותיקון מס' 137

א. השיקולים בעד עבירה אחת

ראשית כול, הקושי המוכח לקבוע הבחנות נורמטיביות ראויות ותקפות.¹¹⁰¹ שיקול אחר עשוי להיות יצירת יכולת מרבית להתאים את העונש למעשה ולעושה, שכן הרשות השופטת יכולה להביא בחשבון את מכלול הנתונים, כדבריו של Lord Kilbrandon:

There does not appear to be any good reason why the crimes of murder and manslaughter should not both be abolished, and the single crime of unlawful homicide substituted; one case will differ from another in gravity, and that can be taken care of by variation of sentences downwards from life imprisonment.¹¹⁰²

¹⁰⁹² ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 681.

¹⁰⁹³ ראו §1, §2, Kap. 3.

¹⁰⁹⁴ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש שאחרי 942.

¹⁰⁹⁵ כאמור, לפי המשפט האנגלי, המתה בכוונה היא רצח עם מאסר עולם חובה, ואילו המתה בכוונה בהתקיים הגנה חלקית, כגון קנטור או אחריות מופחתת וכן המתה בפזיזות, דינה מאסר עולם כעונש מרבי; כך גם המשפט האירי, ראו הטקסט הצמוד לה"ש 883 ואילך.

¹⁰⁹⁶ מודל זה היה קיים במשפט הרומי, הקאנוני. גם קיקרו אימץ מודל זה שמבחין בין הריגה שהיא המתה מוקלת במצב של כעס, רוגז והתרגשות עזה (on impulsio) לבין רצח שהיא המתה מוחמרת ובסיסית; ראו ALLFELD, לעיל ה"ש 542, בעמ' 13. את המודל הזה מציע Rüdiger Deckers, Thomas Fischer, Stefan König & Klaus Bernsmann, *Zur Reform der Tötungs delikte Mord und Totschlag – Überblick und eigener Vorschlag*, NSStZ 2014, 9ff; ראו גם ESER, לעיל ה"ש 653, בעמ' 106; MEIER, לעיל ה"ש 13, בעמ' 131; GRÜN WALD, לעיל ה"ש 543.

¹⁰⁹⁷ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 690–691.

¹⁰⁹⁸ ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 692–695.

¹⁰⁹⁹ המשפט הנורווגי מגדיר בס' 233 רישה את ההמתה במחשבה פלילית לעבירה פלילית שהעונש המינימלי שלה הוא חמש שנות מאסר, ובסיפה את ההמתה בנסיבות מחמירות, כגון כוונה תחילה (premeditation) שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עד 21 שנים.

¹¹⁰⁰ ראו (1998) Offences Against the Person Bill; Law Commission No. 237, לעיל ה"ש 852; Law Commission No. 304, לעיל ה"ש 20, שהציעו להבחין בין המתה בכוונה, לרבות הלכת הצפיות, שהיא רצח, לבין המתה בפזיזות שהיא הריגה. ועדות אלה הציעו את הצורה השלישית של המתה ברשלנות שאינה רלוונטית כאן.

¹¹⁰¹ ראו לעיל, הטקסט הצמוד לה"ש 10–13, על האמירות שלפיהן המשפט לא הצליח במהלך מאות ואלפי שנים להציע הבחנה שאין עוררין עליה בין הצורות השונות של המתת אדם.

¹¹⁰² ראו 72–73, 41, 2 All E.R. [1974] 2, 98, 55, AC [1975] Hyam v. D.P.P.

כאשר השופט סבור, על סמך הראיות שהובאו בפניו, שבוצעה המתה מוחמרת או מוקלת, אין הוא צריך "לצאת למסע ציד אחרי רכיב מחמיר או מקל" ¹¹⁰³ כדי לבחור בעבירה המתאימה ולהצדיק את ההחמרה או ההקלה, והוא יכול להרשיע בעבירת ההמתה ולהטיל את העונש ההולם. השופט לא נאלץ לפתח גישה לתיקון שלילי או לתיקון חיובי לצמצום רכיב מחמיר או להרחבת רכיב מקל כפי שנעשה במשפט הגרמני. ¹¹⁰⁴ השופט גם לא נאלץ לקבוע שרכיב מסוים מתקיים אף שהוא אינו מתקיים, כדי שיהיה ניתן להרשיע בעבירה מוקלת, כפי שנעשה במשפט הגרמני ¹¹⁰⁵ ובמשפט האנגלי ¹¹⁰⁶ בנוגע לרכיב של אחריות מופחתת המבוססת על קיומה של הפרעה נפשית חמורה או על הקנטור המתמשך במקרה של המתת המתעלל בידי קורבן ההתעללות או בן משפחתו. ¹¹⁰⁷

נוסף על כך, הגדרה קזואיסטית של הרצח כהמתה מוחמרת ושל הריגה בנסיבות מקילות כהמתה מוקלת מאפשרת קיומם של מקרים חמורים או קלים שאינם נופלים בגדר העבירה החמורה או העבירה הקלה. לפי דבריו של שטראטיוורט, "קריטריונים מדויקים מספיק אינם בנמצא. ככל שהתנאים לסיווג המתה במחשבה פלילית לרצח מדויקים יותר, הם זקוקים לצמצום רב יותר באמצעות חריגים". ¹¹⁰⁸ ייתכנו מקרים שבהם ההבחנה הטכנית בין רצח לבין הריגה מאפשרת קיומה של הריגה אף שהמקרים חמורים ומצדיקים הרשעה ברצח. ¹¹⁰⁹ אולם הגדרה אחת להמתת אדם מסירה מכשול זה. למשל, בעניינם של בוחבוט, בסו וחדד ¹¹¹⁰ בית המשפט יכול להרשיע בהמתה במחשבה פלילית ולהטיל את העונש ההולם, ואין חשש שהתביעה תאשים בגין העבירה החמורה ביותר ותגביל את בית המשפט ותחייבו להטיל את העונש החמור יותר; בית המשפט אינו צריך להיות תלוי בטוב ליבה וכתום ליבה של התביעה בבחירת העבירה נושא כתב האישום, כפי שנעשה בעניין בוחבוט. יתרה מזאת, התביעה אינה פועלת תמיד בדרך הראויה, וייתכנו מקרים של טעות שבהם התביעה תגיש כתב אישום בגין רצח כאשר המקרה הנדון אינו מתאים לכך. בית המשפט אינו מוכרח להרשיע את הנאשם בעבירה חמורה ולהטיל עליו עונש חמור מזה שמגיע לו, בשל הגדרת העבירה, כפי שנעשה בעניין תומא, באומרו: "כשלעצמי, אין דעתי נוחה מההוצאה שאליה הגעתי מכוח גזירת-הדין, תוצאה המחייבת לאשר למערער גזר-דין של מאסר עולם. אין דינו של המערער במקרה דנא כדין עבריינים למיניהם המוכנים לקטול אדם בנפש חפצה על-מנת ליטול ממנו את ממונו או כדין הנוטל נפשו של חברו מחמת טובת הנאה כלכלית או אחרת העשויה לצמוח לו מכך. במקרה שלפנינו קדמה למעשה הקטילה פרובוקציה חמורה שעשויה היתה להוציא מגדרו את המערער בהתחשב באישיותו, רקעו ובסיבתו, אם כי לא הגיעה לדרגת הקנטור הדרושה לפי החוק, ולא צמחה למערער כל טובת הנאה אישית עקב מעשהו;

1103 ראו Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 93; גם Arvanitis, לעיל ה"ש 1, בעמ' 120–121; Reizel, לעיל ה"ש 636, בעמ' 72.

1104 על התיקון השלילי והתיקון החיובי ראו בהמשך, הטקסט הצמוד לה"ש 1611–1616.

1105 ראו למשל הדיון בתופעה של "המתה מתוך מניע שפל" ו"המתה תוך עורמה", אצל Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 37; גם Arvanitis, לעיל ה"ש 1, בעמ' 120.

1106 ראו לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 848.

1107 ראו עניין Ahluwalia, לעיל ה"ש 1043, ועניין Hobson, לעיל ה"ש 1043.

1108 ראו לעיל ה"ש 13.

1109 ראו גם People v. Conroy (No 2), [1981] IR 160, 163.

1110 ראו ע"פ 6353/94 בוחבוט נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(3) 647 (1995); תפ"ח (מחוזי ת"א) 416/93 מדינת ישראל נ' בסו, פ"מ התשנ"ד(3) 281 (1994); ע"פ 4419/95 חדר נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 752 (1996).

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 221

אילו הוחלה בישראל הלכת האחריות המופחתת, הייתי מקל עם המערער בהרבה במה שנוגע לתקופת המאסר שראוי הוא לשאת.¹¹¹¹ וכן, בעניינים **לדאני**, **קיסר ואייזמן**,¹¹¹² כאשר נקבע כי "למרבה הצער לא אימץ המחוקק שלנו את האחריות המופחתת, אשר כבר נקלטה וקנתה שביתה במדינות אחרות, והמאפשרת התחשבות בענישה במקרים מסוג זה. לא פעם בוטאה במדינתנו המשאלה, כי ראוי שייתן המחוקק דעתו לשאלה זו, וכי יינתנו בידי בית המשפט כלי ענישה מתאימים לאותם המקרים, הראויים להתחשבות מפאת מצבם הנפשי או מחמת נסיבות אחרות מיוחדות, אשר מעמידות אותם בדרגת אחריות מופחתת".

זאת ועוד, הבחנות חקיקתיות בין צורות שונות של המתה, למשל חקיקת העבירה של המתה באחריות מופחתת, כגון קנטור, תאפשר לנאשם להעלות טענות רבות בדבר פועלו והתנהגותו של הקורבן, בייחוד כאשר מדובר באישה, שמצדדו בהרשעה בהמתה מוקלת, ולכן בהרשעה זו יש למעשה משום גינוי הקורבן (blaming the victim), במובן שהקורבן הביא את האסון על ראשו וגם הוא אשם במותו ואחראי לו.¹¹¹³

זאת ועוד אחרת, אין עוד מקום לקריאותיהן של הפסיקה ושל הספרות המשפטית לערוך רפורמה בעבירות ההמתה כדי לטפל בתופעה מסוימת כראוי: למשל, אין עוד מקום לאמירתו של בית המשפט שראוי שהמחוקק יקבל את מודל האחריות המופחתת,¹¹¹⁴ או ראוי שהמחוקק יתערב ויגדיר את הרכיב של כוונה תחילה הגדרה ראויה יותר, למשל בבחירת מבחן סובייקטיבי, אובייקטיבי או שניהם יחד כאשר לרכיב של היעדר קנטור,¹¹¹⁵ או הקריאה של הפסיקה אל המחוקק לערוך רפורמה בחלופת הרצח של המתה אגב ביצוע עבירה אחרת,¹¹¹⁶ ובית המשפט ירשיע בעבירת ההמתה ויטיל את העונש המתאים.

לואף-זו, בית המשפט אינו צריך להתערב בפועלה של התביעה ולמתוח ביקורת עליה על שהגישה כתב אישום בגין עבירה לא מתאימה,¹¹¹⁷ ובית המשפט יכול להרשיע בעבירת ההמתה ולהטיל את העונש ההולם.

נוסף על כך, גם המחוקק יוצא נשכר, שכן אין עוד דיונים וויכוחים, בין עניינים-מקצועיים ובין אידאולוגיים, בדבר סיווגה של תופעה מסוימת. למשל, סעיף 300א בתור רצח עם עונש מופחת או שמא הריגה או אף הריגה בנסיבות מקילות.¹¹¹⁸ אף אין חשש מחקיקה הנובעת או המושפעת משיקולים פוליטיים, והמערכת השיפוטית תטפל בכל התופעות בהתאם. מודל זה ראוי במיוחד כאשר המערכת

1111 עניין **תומא**, לעיל ה"ש 1071, בעמ' 151.

1112 עניין **לדאני**, לעיל ה"ש 1025, בעמ' 38–39. על דברים אלה חזר השופט בייסקי בעניין **קיסר**, לעיל ה"ש 1025, בעמ' 354; עניין **אייזמן**, לעיל ה"ש 1025, בעמ' 463.

1113 ראו גם Blom-Cooper & Morris, לעיל ה"ש 1082.

1114 ראו לעיל פסקי הדין שבה"ש 1112.

1115 ראו ע"פ 3071/92 **אזולוס נ' מדינת ישראל**, פ"ד נ(2) 573 (1996); דנ"פ **ביטון**, לעיל ה"ש 278.

1116 ראו גם עניין **אבו זייד**, לעיל ה"ש 688, פסק דינה של השופטת פרוקצ'יה; עניין **טמטאווי**, לעיל ה"ש 690.

1117 כפי שנעשה בעניין **בסו**, לעיל ה"ש 1110.

1118 על הוויכוח ראו הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 41) (אחריות מופחתת), התשנ"ה–1995, ה"ח 2403, כ"ט באייר התשנ"ה, 29.5.1995; ד"כ לד' (1995) 9593; ד"כ מא, ישיבה שע"א – הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 44), ה' באב התשנ"ה (1 באוגוסט 1995), 11651.

השיפוטית זוכה לאמון ציבורי רב מזה שזוכה לו הרשות המחוקקת, כפי שקיים במציאות הישראלית.¹¹¹⁹

ב. השיקולים נגד עבירה אחת

הדגם של עבירת המתה אחת מחייב מסגרת עונשית בעלת נפח ומרווח מספיקים להתייחסות למקרים הקלים ביותר ולמקרים החמורים ביותר. ברור שעונש חובה לא יוכל לבוא בחשבון בדגם זה. מנגד, קשה לתת ביטוי לחשיבותו של של חיי אדם ללא רצפה כלל. קביעת רצפה מעוררת את הבעיות הכלליות של עונשי מינימום. כמו כן היא כוללת את המחוקק במתח בין הצורך לקבוע רצפה שתיתן חשיבות לערך לבין הצורך לאפשר צדק במקרה הפרטי. אפילו עונש מינימום של חמש שנות מאסר עלול להיות חמור מדי למקרים הקלים ביותר. לעומת זאת עונש קל יחסית הוא בעייתי מבחינת המסר. אומנם הדגם של עבירת המתה אחת מבטיח גמישות ויכולת להתאים את העונש למקרה הפרטי, ובלבד שהיא מאפשרת לחרוג לקולה מעונש המינימום במקרים חריגים, אולם הוא בעייתי מבחינת הטמעת חשיבותו וקדושתו של ערך חיי האדם.¹¹²⁰ הציבור מתרגל לשמוע שעל מקרים שונים של המתה אדם מוטלים עונשים קלים, ולמי שאינם מתעמקים בפרטים (הרוב המכריע של הציבור) המסר בפועל הוא של זילות חיי אדם. למעשה, המסגרת החקיקתית מתייחסת להמתת אדם מתוך עמדה נפשית מגונה כאל כל עבירה אחרת. במידה רבה הביקורת המוטחת בעבירת ההריגה במשפט הישראלי אמורה להתעצם אל מול הדגם הזה, שכן לא רק שאין מבחינים בו נורמטיבית בין קלות דעת לבין אדישות וכוונה, גם אין נותנים ביטוי נבדל לצורות החמורות במיוחד של המתה אדם.¹¹²¹ ההבחנות הבסיסיות בין מקרים שונים השונים מהותית אלה מאלה בחומרתם שהמחוקק עושה אותן, תצטרך הפסיקה לעשות אותן. עד להתגבשות אמות מידה ברורות, מהלך שנים לא מעטות, תשרור אי־ודאות, ועלולים להיווצר הבדלים ניכרים בין בתי משפט שונים. קביעות ערכיות בנושא קריטי לסדר החברתי ורגיש במיוחד מבחינת תחושת הביטחון של הציבור ואמונו בסדר המשפטי, הנעשות בבתי המשפט ולא בידי המחוקק, עלולות לסבול מגירעון מבחינת הלגיטימציה הציבורית. הוועדה המלכותית של אנגליה וויילס 1980 גרסה כי –

As far as we have been able to judge from the memoranda submitted to us the public generally wants murder to be retained as a separate offence. If we were to propose the abolition of the separate crime of murder and its incorporation into a wider offence of unlawful homicide, many people would certainly find it hard to appreciate that the proposal was not meant to weaken the law and would be likely to think that

1119 עם זאת יש לציין כי בפועל משקלו של שיקול זה אינו גדול, שכן המחקר מראה כי חרף האפשרות הזו שופטים נוטים להביא בחשבון בגזירת העונש מספר מוגבל וקטן של נתונים.

1120 ראו גם Criminal Law Revision Committee, 14th Report, לעיל ה"ש 871, פס' 15; Law Commission; Consultation Paper No. 177, לעיל ה"ש 21, פס' 2.31–2.18 בעמ' 30–32.

1121 ראו גם שם, בעמ' 33.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 223

the law no longer regarded the intentional taking of another's life as being especially grave. We recommend that murder should continue to be a separate crime.¹¹²²

יתרה מזאת, עיון בחוק הדני מעלה שמה שנראה בבדיקה לא יסודית כהסדר כוללני ופשטני הוא למעשה מורכב יותר, שכן יש להביא בחשבון את הוראות החלק הכללי הנוגעות להשפעתן של נסיבות מקילות ומחמירות על העונש, שהן דומות לחלק ניכר מהנסיבות המחמירות והמקילות הספציפיות המאפיינות את הצורות השונות של המתת אדם. הנסיבות המקילות מאפשרות לחרוג אל מתחת לעונש המינימום.¹¹²³ מבחינה זו ההסדר בדנמרק מספק הדרכה טובה יותר מהסדר דומה בשיטה שאין בה

1122 ראו Criminal Law Revision Committee, 14th Report, לעיל ה"ש 871, פס' 15.

1123 ס' 81–82 לקוד הפלילי הדני קובע כך:

81. In determining the penalty it shall, as a rule, be considered a circumstance in aggravation

- 1) that the offender is previously punished of significance for the case;
- 2) that the offence is committed by several persons together;
- 3) that the offence is specifically planned or part of extensive crime;
- 4) that the offender intended the offence to have significantly more serious consequences than it did;
- 5) that the offender has shown particularly recklessness;
- 6) that the offence stems from others' ethnical origins, religious beliefs, sexual orientation or similar;
- 7) that the offence stems from the injured party's lawful expressions in the public debate;
- 8) that the offence is committed during the execution of public service or duty or by abusing an official capacity or other special position of trust;
- 9) that the offender has caused another person to participate in the offence by use of force, deceit or by taking advantage of the other person's young age or considerable financial or personal troubles, lack of knowledge, irresponsibility or an existing state of dependence;
- 10) that the offender has taken advantage of the injured party's defenceless position;
- 11) that the offence has been committed by a person who is serving a custodial penalty or is subject to some other criminal legal consequence of a custodial nature;
- 12) that the offence is committed by a former prisoner against the institution or a person employed by the institution.

82. In determining the penalty it shall, as a rule, be considered a circumstance in mitigation

- 1) that the offender had not reached the age of 18, when the offence was committed;
- 2) that the offender is of old age, when use of the ordinary penalty is unnecessary or harmful;
- 3) that the offence verges on grounds for impunity;
- 4) that the offender has acted in excusable ignorance or excusable misinterpretation of legal provisions, which prohibit or require the act;
- 5) that the act is committed in a state of agitation provoked by an unlawful attack or by a gross insult on the part of the injured party or individuals associated with the injured party;

נסיבות מחמירות ומקילות כלליות. אשר להסדר המשפטי בדנמרק – נוסף על עבירת ההמתה הכללית, שהעונש עליה נע בין חמש שנות מאסר למאסר עולם,¹¹²⁴ הוא בכל זאת מקיף צורות מיוחדות של המתת תינוק (שדינה ארבע שנות מאסר)¹¹²⁵ והמתה לפי דרישה (שדינה שלוש שנות מאסר),¹¹²⁶ כאשר העונש המינימלי לשתי התופעות הוא שבעה ימים.¹¹²⁷ אם כן, לפי החוק הדני, לבית המשפט יש סמכות להטיל בגין כמעט כל מעשה של המתת אדם מתוך מחשבה פלילית עונש הנע בין שבעה ימים עד עשרים שנה או מאסר עולם. עם זאת יש לציין כי לפי הדין הדני, במקרה של עונש מאסר עולם שחרור על תנאי אפשרי אחר ריצוי העבירה במשך 12 שנים, במקרה של עונש אחר – אחרי ריצוי של שני שלישים מהעונש,¹¹²⁸ ובמקרים חריגים ויוצאי דופן – אחרי ריצוי מחצית העונש.¹¹²⁹ במקרים של מורשע מסוכן ניתן להטיל אמצעי מנע ובטיחות שמטרתם הגנה על החברה כאשר המשמעות היא שלילת חירותו של המורשע לתקופה בלתי קצובה.¹¹³⁰ ראוי להזכיר גם שדנמרק היא יוצאת דופן בכוח

- 6) that the offence results from use of force, deceit or from taking advantage of the offender's young age or considerable financial or personal troubles, lack of knowledge, irresponsibility or an existing state of dependence;
- 7) that the offence is committed under the influence of strong compassion or emotion or other special information is available about the offender's state of mind or the circumstances of the offence;
- 8) that the offender voluntarily has averted or attempted to avert the danger resulting from the punishable act;
- 9) that the offender voluntarily has reported himself and made a full confession;
- 10) that the offender has provided information that is crucial for solving punishable acts committed by others;
- 11) that the offender has restored or attempted to restore the damage caused by the punishable act;
- 12) that the offender as a result of the punishable act is deprived of a right referred to in Section 79 of this Act or is imposed with other consequences comparable with punishment;
- 13) that the criminal case against the offender, due to no fault of the offender, is not decided within a reasonable time;
- 14) that such a long time has passed since the punishable act was committed, that the use of the ordinary penalty is unnecessary.

ס' 83 מאפשר חריגה מעונש המינימום בהתקיים הנסיבות המקילות. ראו MALENE FRESE JENSEN, VAGN GREVE, GITTE HØYER & MARTIN SPENCER, *THE PRINCIPAL DANISH CRIMINAL ACTS* 28–29 (2006); Hans-Georg Koch, *Rechtsvergleichende Bemerkungen anlässlich der Überlegungen zu einer Reform der vorsätzlichen Tötungsdelikten in Deutschland*, in ABSCHLUSSBERICHT DER EXPERTENGRUPPE ZUR REFORM DER TÖTUNGSDELIKTE (§211–213, 57a StGB) dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Mass im Juni 2015 vorgelegt, p. 596.

1124 ס' 237 לקוד הפלילי הדני.

1125 ס' 238 לקוד הפלילי הדני.

1126 ס' 239 לקוד הפלילי הדני.

1127 ס' 133(1) לחוק הפלילי הדני.

1128 סעיף 38 לחוק הפלילי הדני.

1129 ס' 40a לחוק הפלילי הדני.

1130 ס' 70 לחוק הפלילי הדני.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 225

שהיא מעניקה לרשות השופטת, לרבות הכוח להטיל אחריות פלילית על מעשה שלא היה אסור בעת עשייתו מכוח שיקולי אנלוגיה.¹¹³¹

זאת ועוד, קיים צורך משפטי-חברתי להבחין בין מקרים שונים שיש ביניהם הבדלים איכותיים מבחינת חומרתם היחסית. בפועל, ולמרות החומרה שיש בהמתת אדם מתוך מחשבה פלילית ושוויון הערך של כל הקורבנות, יש מקרים שונים מאוד של המתה מבחינת הדרגה של אשמת העושה – *Tötung ist nicht gleich Tötung*¹¹³² – ולכן לפי עקרון ההלימה (fair labelling principle) יש להבחין בין הצורות השונות של המתה.¹¹³³ נתבונן למשל בהמתת אדם במצב הקרוב מאוד לפטור מוחלט מאחריות פלילית או מתוך קנטור, ונשווה אותם למקרי המתה שמבצע ארגון פשיעה כדי לקדם את מטרותיו, המתה טרוריסטית, המתה מתוך מניע גזעני, המתה מתוך תאוה להמית או תאוות בצע. בין הסוג הראשון לבין הסוג השני קיימים הבדלים מוסריים וערכיים עמוקים שמשתקפים גם בתודעת הציבור. דיני העונשין אמורים לבטא את השקפותיה הערכיות היציבות של החברה באמצעות ביטוי לשוני בין המקרים. ההבדלים בין המקרים יוצרים רמות שונות של ראויות לעונש ושל נחיצות העונש. לא הוגן מבחינת העושים הקלים שהם נכללים בחברותא אחת עם העושים שאינם קלים, ולו מבחינת הקטגוריה הנורמטיבית.¹¹³⁴ לפי הוועדה האירית, ההבחנה בין הצורות השונות של המתה מבטאת עיקרון משפטי, עיקרון מוסרי וגם עיקרון היסטורי מאז קוק והיא חלק מהשקפות החברה.¹¹³⁵ בהקשר זה יש לציין כי כל הצעות החוק הגרמניות, השווייצריות, האוסטריות, האנגליות, האיריות,¹¹³⁶ הניו-זילנדיות¹¹³⁷ ושל ויקטוריה שבאוסטרליה דבקות בהבחנה בין הצורות השונות של המתה וגורסות כי ההבחנה היא “deeply imbedded in our social and legal culture”.¹¹³⁸ אם הבדלים אלה ניתנים להכללה, מתפקידו של המחוקק, כמתחייב מעקרון החוקיות (כביטוי לעקרון הפרדת רשויות), לתת להם ביטוי. לפי עקרון הבהירות, הנגזר מעקרון החוקיות, על המחוקק לשאוף להגדרה הבהירה ביותר

1131 ראו ס' 1 לחוק העונשין הדני (1930), שלפיו: “Only acts punishable under a statute or entirely comparable acts shall be punished”.

1132 ראו גם עניין *Howe*, לעיל ה"ש 1013, בעמ' 433; גם Law Commission No. 290, לעיל ה"ש 21, פס' 2.6 בעמ' 10; Law Reform Commission Consultation Paper, LRC CP 17-2001, לעיל ה"ש 884, פרק 1.

1133 ראו ASHWORTH, PRINCIPLES, לעיל ה"ש 21, בעמ' 256, 262–263, ESER; לעיל ה"ש 653, בעמ' 94; MEIER, לעיל ה"ש 13, בעמ' 131; ORMERODE, לעיל ה"ש 21, בעמ' 440–441, Wilson; לעיל ה"ש 841, בעמ' 23–24; SIMESTER & SULLIVAN, CRIMINAL LAW (2007), לעיל ה"ש 41, בעמ' 385; Law Commission Consultation Paper No. 177, לעיל ה"ש 21, בעמ' 27, 33; Law Commission No. 304, לעיל ה"ש 883, פס' 2.19–2.21 בעמ' 22; Law Reform Commission, LRC 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.05 בעמ' 6.

1134 ראו גם ESER, לעיל ה"ש 653, בעמ' 95; MICHAEL ALLEN, CRIMINAL LAW 145–146 (7th ed. 2003); Law Commission No. 304, לעיל ה"ש 20, פס' 2.21 בעמ' 22.

1135 ראו Law Reform Commission, LRC 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.04 בעמ' 6, פס' 1.08 בעמ' 7.

1136 ראו שם, פס' 1.24 בעמ' 11.

1137 Criminal Law Committee New Zealand Report on Culpable Homicide (1976) ה-1137 ההבחנה בין הצורות השונות של המתה ולאמץ מודל של עבירה אחת זכתה לביקורת חריפה מאוד עד כדי כך שהוועדה העוקבת הציעה להשאיר את ההבחנה על כנה – ראו The New Zealand Crimes Consultative Committee Crimes Bill, 1989: Report of the Crimes Consultative Committee (1991) pp. 43–45.

1138 Law Reform Commission of Victoria Homicide (Discussion Paper No. 13, 1988) para. 108 ראו

האפשרות של העבירה ולתת ביטוי להבחנות בין הצורות השונות של המתה אדם,¹¹³⁹ ההבחנה בין התופעות השונות של המתה היא קשה, אך אין מדובר בקושי שלא כדאי להתמודד עימו. עדיפה התמודדות על הרמת ידיים מוחלטת. בסופו של דבר, לא ניתן להימלט מן המלאכה הזו של אפיון המקרה מבחינת רמת חומרתו. אם היא אינה נעשית בשלב הכרעת הדין, יש לעשותה בשלב גזירת הדין, כפי שגם קובע תיקון מס' 113 לחוק העונשין. אם בית המשפט מסוגל לעשות זאת ברמת המקרה הפרטי, גם המחוקק כשיר לעשות כן ברמה של המקרים הטיפוסיים. ואם המחוקק מסוגל להגדיר את הנסיבות המחמירות והמקילות בחלק הכללי בעניין כל העבירות הפליליות, בוודאי הוא יכול לעשות זאת במסגרת הספציפית של עבירות ההמתה. ניתן למנוע קשיחות יתר של ההסדר ולאפשר עשיית צדק במקרה הפרטי גם בלי ויתור מלא או כמעט מלא על הכוונה חקיקתית.¹¹⁴⁰

באשר לטענת גינוי הקורבן (blaming the victim) יש לומר כי הנאשם יעלה תמיד את כל הטענות שלזכותו, לרבות קנטור וחריגה מתנאי ההגנה העצמית, כדי לזכות בהקלה בעונש. במילים אחרות, הנאשם יעלה אותן טענות הן במודל של עבירה אחת והן במודל של יותר מעבירה אחת. יתרה מזאת, תפקידו של בית המשפט, נוסף על התביעה, הוא שלא לפגוע בכבודו של הקורבן שנפטר; אין להפוך את הקורבן לאשם במותו.

זאת ועוד, יש יתרון לתהליך החקיקה על פני השפיטה:¹¹⁴¹ יש עדיפות לחשיבת הרבים ולהליך הרב-שלבי, הגלוי לציבור, הפתוח לתשומות מגוונות והמגבש סיכוי לשינוי דעה, המאפיין את החקיקה. ככל שהחברה הטרוגנית יותר, הביורור הגלוי והמשותף – המאפיין את החקיקה – נעשה חיוני יותר. לא ניתן לסמוך על כך בחברה כזו, בשונה מחברה הומוגנית כמו החברה הדנית, שבתי המשפט ידעו לשקף תודעה חברתית אחידה ושקופה, שלא ברור כלל אם היא קיימת בחברה הטרוגנית ומה טיבה.¹¹⁴² היגד נורמטיבי כזה מבטיח שהרשות השופטת תיתן ביטוי להבדלים המוסריים והערכיים בין המתות שונות, כפי שקבע המחוקק בשמם של האזרחיות והאזרחים. כך גם מובטחים טוב יותר השוויון בפני החוק (דין שונה למקרים שונים) והביטחון המשפטי, שהם היבטים חשובים של עקרון החוקיות. החוק ממלא כך טוב יותר את פונקציית ההדרכה שלו כלפי האזרח, שיכול לחשב טוב יותר את תוצאות מעשיו לפני מעשה ואחרי מעשה, בעת ההתדיינות (צדק דיוני) וכלפי הרשות השופטת. עקרון הפרדת הרשויות מטיל חובה על המחוקק להגדיר את הצורות השונות של התופעות, כדבריו של Ignor, שלפיהם "קביעת האנטי-חברתיות היא עניינו של המחוקק ולא של השופט – מהאחרון נדרש רק יישום החוק, אך לא החלטה ערכית. לפיכך חייב המחוקק להתחשב במאפיינים הקונקרטיים ולא להעביר את ההכרעה מלכתחילה למיישמי הדין".¹¹⁴³

1139 ראו גם ASHWORTH, PRINCIPLES, לעיל ה"ש 21, בעמ' 256; MEIER, לעיל ה"ש 13, בעמ' 131.

1140 ראו גם Albin Eser, *Neue Impulse zur Reform der Tötungsdelikte: ein kritischer Vergleich*, in Law Commission Consultation Paper No. 177; Festschrift für Kargl 91, 104–105 (2015), לעיל ה"ש 21, בעמ' 33; 25 Ise.L.Rev. 662, 678–679; Mordechai Kremnitzer, *Sentencing as a Just System*, 25 Ise.L.Rev. 662, 678–679; 33 (1991).

1141 ראו גם ASHWORTH & MITCHELL, לעיל ה"ש 847, בעמ' 2.

1142 שיטה זו עשויה להתאים גם לשיטה משפטית שאינה מכבדת את עקרון החוקיות, כמו סין, ובמידה מסוימת גם דנמרק.

1143 עמדתו של Ignor, חבר ועדת המומחים הגרמנית לבדיקת עבירות ההמתה, בעמ' 176 Abschlussbericht – der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§211-213, 57a StGB) dem Bundesminister der

ג. חלוקה לשלוש או לשתי עבירות?

מידת ההבחנה הנורמטיבית הנדרשת בדגם דו-שכבתי היא פחותה מבדגם תלת-שכבתי, אך רבה מבדגם של עבירה אחת. ניתן להשאיר מתכונת זו כמות שהיא, וניתן לשכלל אותה (או לסבך אותה) באמצעות הכנסת קווים מנחים או הנחיות לענישה לתוך הצורה הבסיסית על מנת לאפשר לרשות השופטת להבחין בין המקרה החמור במיוחד לבין המקרה שחומרתו רגילה. יש טעם לעשות זאת כאשר יש לכך נפקות מבחינת העונש, למשל כשנקבע עונש של מאסר עולם או עונש מאסר עולם חובה למקרה החמור במיוחד, כפי שנעשה בענייננו בדבר רצח ורצח בנסיבות מחמירות. אולם פתרון כזה אפשרי רק בשיטה משפטית שבה מקובלת גישה כזו בחקיקה. במקום שבו אין היא מקובלת, כמו אצלנו, אין מקום לנקוט אותה, מן השיקול של אחדות ועקיבות בשיטה המשפטית.¹¹⁴⁴

אולם גם הדגם הדו-שכבתי של שתי עבירות אינו נקי מבעיות. הצורה הבסיסית היא בהיקף נרחב מדי ומקיפה מקרים שונים מאוד מבחינת רמת האשמה הבאה לידי ביטוי בהם. כך, במודל השני, המחבר בין הצורה הרגילה והמוקלת ומפריד בינו לבין הרצח (למשל המודל הצפּרתי), הצורה המוחמרת עלולה לסבול מקשיחות יתר. ואומנם, אין כמו הסוגיה שלפנינו כדי להמחיש את חשיבות היחס שבין הנורמה לבין הסנקציה שבצידה, ודווקא מכיוון השפעת הסנקציה על הנורמה, עד כדי כך שהיו מי שאמרו שיש לנו עבירה של רצח משום שיש לנו עונש מוות או מאסר עולם חובה.¹¹⁴⁵ די ברור כי המאמץ לאפיין היטב ובצורה מוגדרת ומפורטת את מאפייני הרצח נבע מכך שלהרשעה ברצח, לעומת הרשעה בהריגה, היו השלכות עונשיות מרחיקות לכת ויוצאות דופן. תולדות התפתחותן של עבירות ההמתה, הן זו הרשמית הנורמטיבית והן זו של ההפעלה של המשפט למעשה, הושפעו במידה רבה מאוד מהרצון להימנע מתוצאה עונשית קשה, שנחשבה ללא צודקת (כללית וכן בהקשר של אי-שוויון או ביישומה במקרה ספציפי). מקור עיקרי לתחושת אי-הצדק היה הקשר ההכרחי בין רכיבים מוגדרים לבין תוצאה עונשית.¹¹⁴⁶ נדרש איזון מוצלח יותר בין שיקולים של מניעה כללית לבין צדק לפרט, בין ביטחון וודאות משפטיים לבין התחשבות בנסיבות מיוחדות המתקיימות במקרה הפרטי ומשפיעות על ראויות העונש ונחיצותו. הכיוון הכללי להשגת איזון כזה הוא ביתר גמישות.

אשר לעתיד, נודעת חשיבות למדיניות המחוקק באשר לעונש בעיצוב ההסדר של עבירות ההמתה: שימור של מאסר עולם חובה מחייב הבחנה בין מקרים רגילים של המתה לבין מקרים חמורים במיוחד של המתה. שימור מאסר עולם (גם לא כחובה) מזמין התייחסות נורמטיבית כלשהי לאפיון המקרים שעונשם מאסר עולם. ולהפך, אם בוחרים באופציה של עבירה אחת, הדבר מחייב מסגרת עונשית רחבה לשם תמרון בתוכה. ההסדר הנכון איננו קביעה של סוגי עונשים תחילה והתאמת העבירות

Justitz und für Verbraucherschutz Heiko Mass im Juni 2015 vorgelegt: "Unrecht zu bestimmen, ist Sache des Gesetzgebers, nicht des Richters – von Letzterem sei lediglich die Subsumtion, aber keine Wertsetzungsentscheidung verlangt. Daher sei der Gesetzgeber gehalten, im Wege konkreter Tatbestände vorzugehen und nicht schon von Beginn an den Rechtsanwender zur Rechtsfortbildung zu zwingen".

¹¹⁴⁴ על הנחיות לענישה ראו רות קנאי "הנחיות לשופט בהפעלת שיקול דעתו בקביעת העונש" מחקרי משפט ה' 234 (התשמ"ו).

¹¹⁴⁵ Eser, ראו לעיל ה"ש 653, בעמ' 27–28.

¹¹⁴⁶ ראו שם, בעמ' 54.

לעונשים אלה, אלא קביעת העבירות לפי המתחייב לפי שיקולים של הגנת ערך החיים, שיקולי אשמה, מניעה כללית ושיקום והתאמת העונשים למסגרות נורמטיביות אלה. מכאן שההבדלים הרבים מבחינת האנטי-חברתיות של המעשה, ובעיקר חומרת האשמה, הטמונים בתופעות השונות של ההמתה מחייבים נטישת הדגם הדו-שכבתי. קיימות תופעות חמורות במיוחד של המתת אדם, תופעות בעלות חומרה רגילה של המתת אדם וכן תופעות מוקלות של המתת אדם. השוני בין התופעות של המתה חייב לקבל ביטוי בחוק; אין לנהוג בשוויון בין לא שווים, ולכן אין לכרוך יחד בקטגוריה אחת תופעות המתה ברמות שונות מאוד של אשמה. מכאן שהטענות שהועלו נגד הדגם של עבירה אחת יפות, במידה מסוימת, גם לדגם הדו-שכבתי. המסקנה היא דחיית המודל הדו-שכבתי, נוסף על דחיית המודל של עבירה אחת.

השאלה הקשה עתה היא זו: כיצד על המחוקק למלא תפקידו זה – האם ביצירת שלוש קטגוריות נורמטיביות נבדלות לחלוטין, בדומה למודל שלוש הדרגות? או שמא נדרש דגם שהוא מגוון ומורכב יותר גם מבחינת היחס בין הצורות השונות, דגם שאינו בנוי על הבחנה אחת מכרעת בין הריגה לבין רצח. כדי לבחון תשובה לשאלה זו יש תחילה לאתר את מטרות ההסדר.

המטרה העיקרית של ההסדר היא לקיים, בה בעת ובניסיון לתת להם ביטוי מרבי, את שני הערכים של חיי אדם וכבוד האדם: הראשון, החשיבות המיוחדת, העליונה, ששיטת המשפט מייחסת לחיי אדם ומכאן החומרה המיוחדת שבה היא מתייחסת להמתת אדם מתוך עמדה נפשית מגונה – כוונה או אדישות; השני, כבוד האדם של העושה, כפי שהוא מתבטא בשמירת אמונים לעקרון האשמה ולמידתיות ובנכונות (אולי מחויבות) השיטה המשפטית לראות גם בממית אדם מי שראוי להשקיע בשיקומו ולאפשר לו בתנאים מסוימים לחזור לחברה. בכך ניתן ביטוי לייחודו של האדם כמי שמסוגל להשתנות.

ייתכן שאי אפשר לקיים במסגרת ההסדר הנורמטיבי של עבירות ההמתה את שתי המטרות האלו במלואן, כפי שעולה מן היחס שבין המטרה המשקמת של העונש לבין הערך הסמלי של מאסר עולם במשמעותו החריפה והמלאה: שופך דם האדם מאבד לצמיתות את הזכות להימצא בחברתם של בני אדם חופשיים. לא נכון לוותר על הערך הסמלי החשוב הזה, אך מתבקש למצוא פתרון מעשי מאוזן יותר באמצעות כלל ההסדרים לטיפול במקפח נפש שצריכים לאפשר, כעבור זמן, מתן ביטוי לשיקול השיקומי. מחד גיסא דווקא בעבירות נגד החיים, יותר מבעבירות אחרות (לדוגמה עבירות נגד הרכוש), ייתכנו מצבים שונים ומגוונים מבחינת אשמתו של העושה, וענישה מחמירה במקרים של אשמה מופחתת אינה מתיישבת עם עקרון האשמה ואף יוצרת שוויון בין מי שאינם שווים, ומאידך גיסא הסוגיה של הגנה על חיי אדם נוגעת בעצב רגיש ביותר של החברה. לאחר ככלות הכול, ההתארגנות החברתית נועדת, בראש ובראשונה, ומעל לכול, להגן על חיי אדם, כדבריהם של קאנט ופיכטה.¹¹⁴⁷ בהתמודדות המשפטית עם עבירות ההמתה יש כדי להשפיע על תחושת הביטחון הקיומי של הציבור ועל מידת הביטחון והאמון שלו בסדר המשפטי. אין להתעלם גם מכך שהציבור יכול לראות בעונשים על עבירות ההמתה בחוק אמת מידה ליחסו של המשפט לחיי אדם. עם זאת יש לנהוג זהירות בממצאים ובמסקנות המתייחסים לתודעת הציבור, ובשתי רמות: תחילה יש לוודא, עד כמה שהדבר ניתן, שמה

¹¹⁴⁷ על גישתם של פיכטה ושל קאנט, ראו Ghanayim, *Excused Necessity in Western Legal Philosophy*, לעיל ה"ש 166, בעמ' 41, 45.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 229

שמייחסים לציבור אכן משקף את עמדותיו, ואחר כך – שעמדות הציבור עומדות במבחן הנורמטיבי-ערכי של חוקתיות. מכאן הצורך באיזון עדין ומורכב בין שתי מטרות חשובות אלה כדי למקסם ככל האפשר את שתייהן בלא לפגוע מהותית אף באחת מהן. מטרות נוספות הן חוקיות ומה שהיא משרתת, כלומר בהירות וודאות של הדין, וצדק במקרה האינדיווידואלי. בין מטרות אלה יש מתח, והן ניתנות להגשמה יחסית רק בהתחשבות הדדית שלהן זו בזו, ועוד נשוב לענין זה. יוצא אפוא שהשיקולים העיקריים לעניין זה הם מתן ביטוי ברור ומובהק לחשיבות הערך של חיי אדם ולחומרה המיוחדת של פגיעה נפשית בו (על חשבון המשקל המיוחד לרכיבים המחמירים כשלעצמם) ומתן ביטוי בד בבד להבדלים מובהקים במידת המגוננות, כלומר האשמה, שבמעשי המתה שונים.

דרך נוספת להידרש לסוגיית המבנה הראוי היא לבחון אותה מבחינת מטרותיה השונות של הענישה. מבחינת האפיון של עבירות ההמתה, תפיסה של מניעת היחיד תוביל לגישה המדגישה גמישות מרבית, שיקול דעת רחב מאוד לרשות השופטת, הימנעות מחקוק מקביעת רכיבים מחמירים ומקילים עם תוצאות עונשיות מחייבות והתחשבות רבה במיוחד בהערכת מסוכנותו של העושה בעתיד.¹¹⁴⁸ משום שגישה עונשית זו בנויה על ספקולציה בנוגע לעושה האינדיווידואלי, היא המתאימה פחות להתוות את ההסדרה החוקית. לעומת זאת הן גישה גמולית והן גישה של מניעת הרבים (גם משום הפונקציית המדריכה והמנחה שהיא מבקשת למלא) ידחפו למעורבות גדולה יותר של המחוקק, לאפיון מובהק (כל גישה לפי דרכה) של הצורות העברייניות ולהגבלת שיקול הדעת השיפוטי.¹¹⁴⁹ כשם שלא ניתן לסלק אף אחת מתפיסות הענישה בתחום שיקול הדעת השיפוטי, כן ראוי שהמחוקק יאזן בין הקטבים שהן מושכות אליהם: החלטה שיפוטית ההולמת את המעשה ואת העושה

מחד גיסא ומסגרת נורמטיבית המתאפיינת במוגדרות, במסוימות ובוודאות מאידך גיסא. הסדר ראוי צריך לעמוד לא רק במטרות היסוד שלו – הגנה על שני הערכים של חיי אדם ושל כבוד אדם – אלא גם במטרות הענישה ובמה שנובע מהן. שיקולים נוספים הם הימנעות מימורה לקבוע הכללות מוחלטות שיש להן תוצאות עונשיות הכרחיות, כלומר הכנסת יסוד של גמישות והערכה מכלולית לעבירה שעונש חובה בצידה; יצירת תחום של חפיפה בין צורות ההמתה החמורות – הרצח והרצח החמור – שהעונש על שתיהן הוא מאסר עולם, בתוך כדי הבחנה בין עונש מרבי לעונש חובה, המותנה בבחינת המכלול הנסיבתי המלא ובמידת האשמה הנשקפת ממנו; הדרכה של הרשות השופטת (ולכן אי-הסתפקות באפיון מהותי כללי, בשונה מהמודל השווייצרי) מבלי לכבול את ידיה. הסדר ראוי צריך לעמוד לא רק במטרות היסודיות שלו, כפי שהוזכרו, ובתפיסות הענישה המגוונות (וכפי שכבר ראינו לא ניתן להגשים במלואן את כלל המטרות אלא רק לחתור לאופטימום של הגשמה חלקית שלהן). עליו להצטיין גם במעשיות ובקלות היחסית של יישומו ומימושו. ככל שמאפיין כלשהו קשה יותר להוכחה, כך יהיה יישומו מקרי יותר. בהקשר זה יש להצביע על יתרון יחסי שיש למאפיינים אובייקטיביים על פני מאפיינים סובייקטיביים: הם נתונים פחות למניפולציה. ככל שהסדר פשוט יותר, רב הסיכוי שהוא ייאכף (בידי כלל הגופים האוכפים) באופן ההולם את מתכונתו הנורמטיבית ובאופן

1148 ראו קנאי "היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה", לעיל ה"ש 103, בעמ' 39, 58–70, Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 69–73.

1149 ראו קנאי "היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה", לעיל ה"ש 103, בעמ' 57–58, 70–76, Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 67–68, 70–73.

שווה יותר, ושהמציאות השיפוטית תעלה בקנה אחד עם זו העובדתית. גם בענין זה אין מדובר ביתרון שאין בצידו חיסרון: מחיר הפשטות יכול להיות שהמאפיין איננו משקף בדיוק ובמלואה את המהות שהוא אמור לגלם. שיטה טובה צריכה גם כאן לשאוף לפתרון מאוזן.

ספק רב אם עבירת ההריגה במתכונתה עובר לתיקון מס' 137 היא צורה בסיסית הראויה לשימור.¹¹⁵⁰ כדי לתת ביטוי לחשיבות המיוחדת של הערך של חיי אדם ולעקרון האשמה בעת ובעונה אחת – הקטגוריה שעניינה המתה מגונה של אדם צריכה להיות עבירה מדורגת, שבנויה מצורה בסיסית של רצח ומצורה מוחמרת של רצח בנסיבות מחמירות. הקו המפריד בין שתי הצורות הללו אינו צריך להיות הרמטי. לשתייהן משותף עונש מיוחד, שאמור לבטא את החומרה המיוחדת שבקיפוח מגונה של חיי אדם – מאסר עולם. במקרה של רצח בנסיבות מחמירות הוא עונש חובה, אלא שכדי למנוע קשיחות יתר ולאפשר עשיית צדק למקרה הפרטי, הנסיבות המחמירות אינן מביאות אוטומטית ובהכרח לתוצאה העונשית הכרוכה בהן בדרך כלל. הן אינדיקטיביות לדרגת אשמה חמורה ביותר, אך אין הן מסוגלות להבטיח את התקיימותה בכל מקרה ומקרה; מדובר במקרים לדוגמה (Regelbeispiele). ללמדנו שבדרך כלל התקיימות המאפיין המחמיר מוביל להרשעה ברצח מוחמר עם עונש מאסר עולם חובה, ואילו במקרים מעטים, שבהם בית המשפט סבור שאין זה צודק, הוא מרשיע ברצח רגיל כאשר העונש לכך פחות ממאסר עולם. לכן כאשר היא אינה מתקיימת בפועל בשים לב לכל הנסיבות הרלוונטיות, המקרה נסוג אל תוך הצורה הבסיסית.¹¹⁵¹ זהו לקח מהניסיון ההיסטורי. הניסיון מלמד שהגדרה של עבירת הרצח בתור הריגה בנסיבות מחמירות, המבוססת על אפיון ברור ומדויק של הרכיבים המחמירים (הגדרה קזואסטית), שבהתקיימם מתחייבת הרשעה ברצח ועונש החובה שבצידה, היא בעייתית. נופלים בתוכה מקרים שאינם צריכים להיות כלולים בה, שכן רמת חומרתם הכוללת אינה גבוהה מספיק.¹¹⁵²

המודל שהיה הנהוג בדין הישראלי עובר לתיקון מס' 137 – הגדרה קשוחה של רצח עם מאסר עולם חובה ללא אפשרות מילוט¹¹⁵³ – מצריך פיתוח של מנגנוני מילוט שונים מלבד מה שנאמר בחוק כדי להסיר את תוצאותיה הקשות. עם הזמן נוצר פער ניכר בין החוק לבין אופן יישומו, פער הנדרש לשם עשיית צדק. אין זה מצב ראוי מבחינת שלטון החוק ועקרון החוקיות. בעייתיות זו הביאה את המחוקק השווייצרי לוותר על הגדרה קזואסטית של עבירת הרצח ולהחליפה באפיון כללי של המתה חסרת מעצורים, המבטאת מגוונות מיוחדת.¹¹⁵⁴ הבעיה היא שאפיון כללי כזה הוא עמום למדי, אינו בהיר דיו ואינו מספק הדרכה ברורה להבחנה בין רצח לבין הריגה.¹¹⁵⁵ ניתן לומר כי ככל שפגיעתו של החוק בזכות יסוד חוקתית חמורה יותר, כך מוגברת חובתו החוקתית של המחוקק להגדיר בבהירות

1150 על עבירת ההריגה בדין המצוי ולביקורת עליה, ראו בהמשך פרק חמישי.

1151 זוהי עמדת המשפט הפיני, שלפי פרק 21 ס' 2, רצח שדינו מאסר עולם הוא המתה אדם בנסיבות מחמירות המנויות בחוק, רק כאשר על פי בדיקה כללית מדובר בעבירה חמורה.

1152 ראו גם Günter Heine et. al., *Alternativ-Entwurf Leben (AE-Leben): Entwurf eines Arbeitskreises deutscher, österreichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer (Arbeitskreis AE)*, GA 2008, 193, (2008) 198.

1153 למעט המקרים שנפלו בגדר ס' 300 הישן לחוק העונשין.

1154 בזמנו כלל המחוקק השווייצרי גם את המסוכנות המיוחדת, אך בשנת 1989 ביטל אותה בשל עקרון האשמה; ראו, לעיל הטקסט הצמוד לה"ש 676.

1155 ראו גם Heine, לעיל ה"ש 1152, בעמ' 209.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 231

הרבה ביותר האפשרית את התנאים לפגיעה, שאם לא כן – אין היא מידתית.¹¹⁵⁶ על קרניה החדות של הדילמה בין רכיבים מוגדרים היטב לבין מאפיינים כלליים, היטיב לעמוד המלומד השווייצרי שטאטינוורט, ולפיו: "קריטריונים מדויקים מספיק אינם בנמצא. ככל שהתנאים לסיווג המתה במחשבה פלילית לרצח מדויקים יותר, הם זקוקים לצמצום רב יותר באמצעות חריגים. ככל שהחוק מנוסח בכלליות, גבולות הרצח לא ברורים".¹¹⁵⁷

המסקנה היא שהתופעות של המתה בכוונה ובאדישות והתופעות של המתה מוחמרת יקבלו ביטוי במתכונת של עבירה בסיסית – רצח – ועבירה הנגזרת ממנה – רצח בנסיבות מחמירות. המתכונת של מבנה מדורג, ובמיוחד כשהפרדה בין הדרגות אינה מוחלטת, מפחיתה במידה מסוימת את חשיבותן של הנסיבות המחמירות. הפחתה יחסית כזו ראויה, שכן היא תורמת להישארותו של מרכז הכובד בערך המוגן שנפגע ובחשיבותו העליונה, שהוא חיי אדם, ואין בכך זילות בו.

באשר לתופעות המוקלות של המתת אדם, מקומן לא יכירן במסגרת עבירת הרצח, שכן הכללתן במסגרת זאת תגרום עוול לממיתים בנסיבות יוצאות דופן ומיוחדות. מנגד, אם פורסים את עבירת הרצח על מקרי המתה כאלה – שוחקים את הסטיגמה המיוחדת של הביטוי רצח ומרופפים את הטאבו המיוחד בחריפותו שהיא אמורה ליצור.

במקרים האמורים פוחתות במידה ניכרת הן האשמה והן הנחיצות בעונש, שכן ההמתה אינה אדקוויטית, כלומר אינה משקפת את אישיות העושה אלא את הנסיבות החיצוניות יוצאות הדופן, ובמקרה של סטייה מתנאי ההגנה העצמית או של קנטור גם את תרומתו של הקורבן.¹¹⁵⁸ נוסף על כך, ההתקפה על הערך המוגן היא בחזית צרה יותר (ההמתה אינה משקפת התנכרות כללית וכוללת לערך של חיי אדם), והפגיעה באמון הציבור בסדר המשפטי וחרדת הציבור קטנות יותר. מלבד זאת, ההקלה אינה מתבקשת על יסוד רכיב אחד, שהוא בסיס רעוע מדי להסקת מסקנות על חומרת האשמה ומידת המסוכנות, אלא על יסוד סיטואציה מורכבת בכללותה. גם המחקר המשווה וההתפתחות ההיסטורית מעניקים תמיכה למסקנה זו. אם כן, ההמתות המוקלות יאוגדו בעבירה פלילית אחת ששמה המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.

ד. השיקול המרכזי להחמרה: אנטי-חברתיות, אשמה (מגוונות מיוחדת) או שיקולי ענישה אחרים בעיקר מסוכנות מיוחדת? אשמה!

העונש הפלילי הוא הגמול על האנטי-חברתיות המלווה באשמה (עקרון ההלימה), כאשר שיקולי הענישה נוסף על גמול הם המניעה האינדיווידואלית (של העושה עצמו) והמניעה הכללית – הן בפן החיובי שלה של מתן תוקף לחוק ולערך שנפגעו מן העבירה, והן בפן השלילי של הרתעת הרבים. העונש הפלילי, שנקרא גם העונש המוצדק, הוא עונש מסגרת שיש בה תקרה (בשיטה שבה עונשי

¹¹⁵⁶ ראו גם שם, בעמ' 219, Tonio Walther, *Vom Beruf des Gesetzgebers zur Gesetzgebung – Zur Reform der Tötungsdelikte und gegen Fischer et al.*, NStZ 2014, 368.

¹¹⁵⁷ ראו לעיל ה"ש 13.

¹¹⁵⁸ ניתן לחשוב גם על המקרה של המתה מתוך ייאוש עמוק, אולם מקרה זה נראה לנו בעייתי, כי הוא פותח פתח רחב מדי משום שאינו מוגדר ומובהק כמו הקנטור, ולכן צריך אולי להגדיר ביתר דיוק את המקרים הטיפוסיים.

מקסימום בלבד), ואפשר שתהיה לה רצפה (בשיטה שבה עונשי מינימום ועונשי מקסימום) – שתהן נקבעות באמצעות עקרון הגמול. אנו סבורים כי ראוי להעניק משקל בכורה בתחום השיקולים לחומרה (ובהמשך גם לקולה) לאשמת העושה.

במשפט האנגלו-אמריקאי קיימת מגמה המזהה את האשמה עם היסוד הנפשי, ולמעשה זוהי התפיסה של אשמה פסיכולוגית.¹¹⁵⁹ זו גישה צרה מדי שאינה מבטאת את מלוא משמעותו של הביטוי. האשמה מביאה לידי ביטוי את היכולת הנפשית של העושה להתנהג לפי כללי המשפט. היא נורמטיבית ומתבטאת בין היתר בראויות לגינאי העושה על מעשהו האנטי-חברתי. ככל שהעושה ראוי לגינוי חריף יותר¹¹⁶⁰ – בשים לב לטיב המעשה, ליסוד הנפשי שליווה אותו, למניעיו ולמטרותיו – כך מוחמרת אשמתו, ולהפך.¹¹⁶¹ משום שבעבירה של מחשבה פלילית העושה (השפוי בדעתו) מודע ליסודות העבירה, הוא ממילא מודע לטיבה האנטי-חברתי. לכן אשמתו מכסה את ממדי האנטי-חברתיות, שהיו בתחום מודעותו.

האנטי-חברתיות של העבירה מורכבת הן מהאנטי-חברתיות של המעשה והן מהאנטי-חברתיות של התוצאה. האנטי-חברתיות של התוצאה מורכבת מן הפגיעה בערך החברתי המוגן, ובענייננו המתה אדם. מבחינה זו האנטי-חברתיות של התוצאה בכל תופעות ההמתה זהה,¹¹⁶² למעט מקרים אחדים, כגון המתה אגב יצירת סכנה קונקרטית לחיי אנשים נוספים או פגיעה בחיי רבים. האנטי-חברתיות של המעשה מורכבת מגורמים שונים, כגון היסוד הנפשי שבו פעל העושה, צורת הפגיעה בערך החברתי המוגן (למשל באכזריות או בתוך כדי יצירת סכנה מופשטת לחיי אדם נוספים) ועוד. רמת האנטי-חברתיות במעשהו של מי שנוסף על גרימת מותו של הקורבן גרם לו גם סבל מיוחד בשל התאכזרות גדולה בממעשה המתה נטול התאכזרות.¹¹⁶³ עם זאת מבחינת האנטי-חברתיות, בהמתה הכרוכה בקיפוח חיי אדם מתוך עמדה נפשית מגונה – רמתה גבוהה מאוד כשלעצמה, ומה שמתווסף אליה יכול להגביה עוד אך אינו יכול להיות בעל משקל מכריע לחומרה.¹¹⁶⁴

¹¹⁵⁹ לפי תפיסה זו, היסוד העובדתי עצמו הוא אובייקטיבי ואין מגולמת בו אשמה או אנטי-חברתיות. האשמה נקבעת לפי יחסו הנפשי של העושה לנתונים האובייקטיביים, והאנטי-חברתיות נקבעת לפי אי-התקיימותם המפורשת של הסייגים לאחריות פלילית. להרחבה ראו גנאים **ההבחנה בין הצדקה-בדין לבין סליחה-בדין**, לעיל ה"ש 25, בעמ' 35.

¹¹⁶⁰ אנו דוחים את עמדתו של WITT, לעיל ה"ש 607, בעמ' 109–113, שלפיה המונח "מגונות" אינו בהיר ואינו ראוי להיות קטגוריה ובסיס לאפיון הרכיבים המחמירים.

¹¹⁶¹ על האשמה הנורמטיבית, ראו גנאים **ההבחנה בין הצדקה-בדין לבין סליחה-בדין**, לעיל ה"ש 25, בעמ' 112–122.

¹¹⁶² EsER, לעיל ה"ש 653, בעמ' 98; Michael Köhler, *Zur Strafbarkeit des Mordes bei "aussergewöhnlichen Umständen"*, JuS 1984, 762, 763 & JuS 1984, 21, 145.

¹¹⁶³ ראו גם 1, Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil, Straftaten gegen die Person, Halbband 17, 19 (vorgelegt von Jürgen Baumann et al., 1970); Hans-Joachim Hirsch, *Zum Aktuellen Stand der Diskussion über die Tötungsdelikte*, in Festschrift für Ruth Rissing-van Saan 219, 230 (2011); C.M.V. Clarkson & Keating, *Criminal Law: Text and Materials* 811 (3rd ed. 1994), Grünwald, לעיל ה"ש 543, בעמ' 168; Clarkson, לעיל ה"ש 21, בעמ' 145.

¹¹⁶⁴ ראו גם 1, Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil, Grünwald, לעיל ה"ש 1163, בעמ' 230, 219, Grünwald, לעיל ה"ש 543, בעמ' 143.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 233

המגוונות המתבטאת במעשה, קרי האשמה, היא הקריטריון המנחה המרכזי בעבירות ההמתה.¹¹⁶⁵ דרגת האשמה צריכה להיות הקריטריון המארגן של עבירות ההמתה: רצח – אשמה חמורה, רצח בנסיבות מחמירות – אשמה חמורה במיוחד, המתה מוקלת – המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה מתוך קלות דעת – אשמה חמורה פחות. היות שהאשמה סופגת לתוכה את ממדי האנטי- חברתיות המיוחדים, לרבות סכנה מוגברת במעשה שהעושה ראוי לגינוי עליהם, הם נבלעים בתוכה ומקבלים במסגרתה ביטוי מספק. לעומת זאת רכיבים של מסוכנות במעשה שאין לגנות את העושה בגינם וכן רכיבים של מסוכנות מיוחדת של העושה שאינם בשליטתו לא יובאו בחשבון לחובתו, כמתחייב מהפונקצייה המגבילה של עקרון האשמה. השימוש בקריטריון האשמה כמרכזי עולה יפה בקנה אחד עם המגמה של הבלטת חשיבותו של הערך המוגן על חשבון רכיבים של אנטי-חברתיות. הבלטה זו של חשיבות הערך של חיי אדם תואמת את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת ועוד, התבססות על האשמה מבטיחה שלא תהיה הפרזה רבה מן המגיע משיקולים תועלתניים. המושג "אשמה" הוא אומנם רחב ועמום, אך ניתן להקטין את הבעייתיות בכך באמצעות צמצום המקרים שבהם יש להידרש לו ישירות, ויש בכך משום שמירה על עקרון הבהירות והוודאות המשפטית.¹¹⁶⁶ כלומר, המחוקק הוא שיקבע ספציפית את המקרים שמשקפים אשמה חמורה, חמורה במיוחד ופחותה, לדרגותיה השונות. הזדקקות ישירה למושג תהיה רק בהקשר של קביעה שמעשה מסוים, בהסתכלות כוללת, אינו משקף דרגה חמורה במיוחד של אשמה, ולכן אינו נכלל ברצח בנסיבות המחמירות למרות התקיימותה של נסיבה מחמירה. נראה כי אין מנוס מסמכות מתקנת כזו שתפקד בבתי המשפט, אין מתאים מהם לכך, ואין לחשוש על פי הניסיון שישתמשו בה שימוש מופרז ולא מוצדק. מוטב שהקביעה תהיה היעדר התקיימות של אשמה חמורה במיוחד ולא רמה פחותה של מסוכנות או של פגיעה בסדר המשפטי. הקביעות החילופיות משמיעות, ודאי עלולות להתפרש, כמפחיתות מחשיבות הערך המוגן, ומכך יש להימנע. הזדקקות להן עלולה גם להרתיע את בתי המשפט מלהשתמש בהן בשל החשש האמור.

ה. העונש על עבירת הרצח

נקודת המוצא של דיון זה היא ששיטת המשפט שלנו מחויבת לגישה רבת-שיקולים בתחום הענישה.¹¹⁶⁷ הטעם לכך הוא שיש גרעין חיוני בכל אחד מהם. כאשר מתמקדים רק באחד מהם, יש חשש להפרזה. הם מאזנים זה את זה ומבטיחים גישה שהיא מאוזנת בסופו של דבר ונמנעת מפתרונות קיצוניים ומוטים. הלכה למעשה נוקטות כל שיטות המשפט גישה כזו. נפנה עתה לדיון בשיקולים המיוחדים לענישת ההמתה.

1165 ראו גם Günter Heine, *Stand und Entwicklung der Mordtatbestände*, in Festschrift für Brauneck, 315, 331 (Mönchengladbach 1999).

1166 לעומת זאת ראו העמדה של אחדים שדורשים ביטול המגוונות בתור רכיב מחמיר; גם Reizel, לעיל ה"ש 636, בעמ' 88; Grünwald, לעיל ה"ש 543, בעמ' 39–48.

1167 ראו ע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 421, 434 (1979); זוהי גם השיטה במשפט הגרמני, ראו BVerfGE 32, 98, 109; להבחנה בין שתי השיטות, ראו Krennitzer & Ghanayim, *Book Review*, לעיל ה"ש 105.

(1) העונש בתוך הקשר

ההתייחסות הנורמטיבית לעבירה אינה עומדת רק לעצמה. היא צריכה להיבחן גם בהקשר הכולל של השיטה. בניית סולם של עבירות ועונשים מתחייבת על מנת שהשיטה תעמוד במבחן המתאם בין חומרת העבירות לחומרת העונשים ויהיה בה היגיון פנימי. ניתן להתחיל מלמטה או מלמעלה. אם מתחילים מלמטה ומגיעים לעונש מאסר ממושך – חמש-עשרה או עשרים שנה לעבירות אחרות, חמורות פחות – ייווצר צורך בקטגוריה עונשית חמורה יותר, ואם מבקשים לבטא את החשיבות המיוחדת של הערך ואת החומרה המיוחדת של העבירה אף בקטגוריה מיוחדת – מאסר עולם. ניתן להתחיל גם בכיוון הפוך – מלמעלה, ואז ניתן לנקוט אחד משני מהלכים: מהלך אחד הוא לקבוע מהו העונש החמור ביותר הבא בחשבון מבחינה חוקתית ולהצמיד אותו לקטגוריה החמורה של המתה. במקרה כזה מתחייב מעקרון המידתיות פיצול של עבירת ההמתה הנעשית מתוך מודעות ושלפיה מתוכה של השכבה העליונה מבחינת החומרה. מהלך אפשרי שני הוא התאמת עונש לעבירה של המתה מתוך אדישות או כוונה, ההולם את חומרתה ושאינו עולה על הבא בחשבון החוקתי. קביעת עונש הולם-חומרה לעבירה יחידה אינו עניין קל, אולם אם מדובר בעונש מרבי בלבד לעבירה כאמור, הצריך להתאים גם למקרה החמור ביותר, זוהי משימה אפשרית, וטווח האפשרויות הוא בין תקופת מאסר ארוכה במיוחד לבין מאסר עולם. במהלך כזה צריך "להשאיר מקום" לעונש הולם לרצח בנסיבות מחמירות.

לא ברור אם יש יתרון בולט לאחת משתי השיטות, אך דומה כי אם אין מתחילים מלמטה, עלולים לנקוט החמרת-יתר שאיננה הכרחית. אפשר שהשיטה הטובה ביותר להגיע לסולם רציונלי היא לנקוט מהלך כפול: הן מלמטה והן מלמעלה, ורק אחר כך לגבש את הסולם הסופי.

(2) העונש כפי שהוא עולה ממטרות הענישה ושיקוליה

(א) גמול

קשה למצוא תחום מובהק יותר ומזמין יותר לשיקול הגמולי מאשר עבירות ההמתה. בשיטה גמולית מודרנית, המבוססת על אשמה, קשה לתאר מקרה שבו הצדק מחייב לגמול לעושה על פשעו יותר מאשר על המתת אדם מתוך עמדה נפשית מגונה.¹¹⁶⁸ בשיטה אינטגרטיבית, המשלבת את השיקול הגמולי בשיקול של מניעה כללית חיובית, אין להתעלם מערכה של תגובה גמולית להחזרת הביטחון בסדר המשפטי, המופר הפרה חמורה במיוחד בביצוע של המתה כזו. מבחינה גמולית מתבקש עונש יוצא דופן בחומרתו, שיהלום את החומרה יוצאת הדופן של המעשה של המתה חמורה. וכאמור, העונש הזה צריך להיות החמור ביותר שבא בחשבון בשיטה המשפטית מבחינה חוקתית.

¹¹⁶⁸ ראו גם Law Reform Commission, LRC 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.29 בעמ' 13. אחדים גורסים כי עונש מאסר עולם הולם את הרצח לפי תפיסה גמולית בלבד, שמשמעה "עין תחת עין", ותפיסה זו מיושנת ואינה ראויה עוד. לפיהם, מדובר כאן בעונש מאסר עולם כתפיסה מטאפיזית את אפיון הרצח כעבירה חמורה ביותר; ראו MEIER, לעיל ה"ש 13, בעמ' 117.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 235

(ב) מניעה כללית – הן שלילית באמצעות הרתעה, והן חיובית באמצעות השבת ביטחון הציבור בסדר המשפטי שנפגע ממעשה העבירה

מבחינה עקרונית המניעה הכללית, במיוחד השלילית (סעיף 140),¹¹⁶⁹ חייבת להיות מוגבלת בעקרון הגמול כמתחייב מעקרון ההלימה לפי סעיף 40 לחוק העונשין. על יחסי הגומלין שבין שיקולים אלה כבר נאמר: "If punishment is to deter it may only do so by giving offenders their desserts" but the "only reason for giving offenders their desserts is that it deters".¹¹⁷⁰ יש משמעות לתכליות אלה גם בהקשר של עבירות ההמתה, כאמור – במגבלה החוקתית והחוקית של גמול. השיקול של מניעה כללית מושך גם הוא (כמוהו כשיקול הגמולי) לכיוון של איתות עונשי מיוחד בגין המתת אדם חמורה – העונש החמור ביותר (לפחות לעומת עבירות אחרות נגד הפרט), ואם רק ניתן – עונש השונה איכותית מן העונשים האחרים. מבחינת המניעה אפשר כי באשר למקרי ההמתה החמורים במיוחד (בייחוד אלה שהם פרי שיקול דעת) אין להסתפק בעונש מאסר קצוב, שכן בנסיבות מסוימות עלול הסיכון הכרוך במעשה המתה להיראות סיכון שניתן, ואף כדאי, להסתכן בו, בייחוד כאשר מביאים בחשבון את הסיכוי – כפי שמעריכו העושה – שלא ייתפס, ואף בהנחה שלא ייתפס. מכאן יכול שיתחייב, לפחות למקרים אלה, עונש מאסר לתקופה שאינה ניתנת לחישוב ודאי מראש. עונש חמור במיוחד, בשונה מהעונש הרגיל, משרת גם את המניעה החיובית, שכן יש בו כדי לסמל את החומרה המיוחדת שבקיפוח חיי אדם ולחזק את ה"טאבו" על המתה. עמדה בלתי מתפשרת של השיטה המשפטית לעניין חשיבותם העילאית של חיי אדם מחזקת את אמון הציבור בסדר המשפטי כמעניק הגנה תקיפה לחשוב שבערכים.¹¹⁷¹

(ג) מניעה אישית

שיקולי ענישה המתמקדים בעושה באספקלריה עתידית, בהדגשת המסוכנות שבעושה. מדובר בנטרול יכולתו לפגוע באזרחים חופשיים (סעיף 40ה), הסרתו מרע (מניעת העושה מביצוע עבירות כאזרח חופשי – סעיף 140) ושיקומו במובן עמוק ומקיף יותר (סעיף 140ד). השיקול המרכזי מבין אלה הוא הסרת העושה מרע (מניעת העושה). הכלל החשוב ביותר הנגזר ממניעת העושה, שעיקרו גם, ואולי בעיקרו, בכבוד האדם, הוא המבטיח לכל עבריין, ובכלל זה רוצח, אפשרות וסיכוי לחזור לחברה,¹¹⁷² על יסוד ההנחה כי מותו האמיתי של האדם, ואולי היחיד, הוא יכולתו להשתנות. כאשר מבטיחים סיכוי כזה גם לרוצח, זהו ביטוי לעדיפות שמעניקים בהקשר זה למניעת העושה על פני שיקולי ענישה אחרים, שאילו השפיעו רק הם, לא היה מקום להענקת סיכוי כזה. אך ניתן לראות בכך ביטוי גם לגישה השואפת לקיום (לפחות פוטנציאלי או בעיקרון) של שיקולי הענישה כולם ולהימנעות מעמדה השוללת לחלוטין אחד מהם. אם תופסים מאסר עולם כמאסר עד צאת נשמתו של הנידון, נשללת המשמעות מן

¹¹⁶⁹ המניעה הכללית החיובית היא גורם שמתחשבים בו כאשר קובעים את המגיע – הגמול.

¹¹⁷⁰ ראו RUPERT CROSS, THE ENGLISH SENTENCING SYSTEM 123 (3rd ed. 1981).

¹¹⁷¹ ראו גם Law Reform Commission, LCR 87-2008, לעיל ה"ש 883, פס' 1.37 בעמ' 17.

¹¹⁷² אולי יש רוצחים שהמעשה שלהם הוא כה חמור שנגזרת ממנו תקופת כליאה מרבית ללא סייג.

המטרות של שיקום ושל הרתעת הנידון, ונותרת רק המניעה הפיזית באמצעות הרחקתו מן החברה החופשית.

בשונה מתפיסות הענישה הקודמות, החשש כאן הוא קודם כול הפוך: שמא תביא ההתמקדות בעושה, בייחוד בשיקומו, להתחשבות מופרזת בשיקול המניעה האישית דווקא לקולה על חשבון שיקולי הענישה האחרים. קל להיווכח שלא ניתן לראות בשיקול זה חזות הכול. כאשר נתפס רוצח שנים רבות מאוד לאחר שרצח, וכל שנותרו שחלפו מאז מעידות בו כי היה מאז לאזרח חיובי ומועיל, כלומר ששיקם את עצמו למופת ואין נשקפת ממנו כל סכנה, לא יצדיק הדבר הימנעות מעונש. במילים כלליות יותר ניתן לומר ששיעורי החזרה להרע בקרב נידונים על רצח והריגה נמוכים מאוד יחסית.¹¹⁷³ נתון זה מתיישב יפה עם אופיים של רוב מעשי ההמתה כמתרחשים על רקע של קונפליקט בין-אישי. אומנם יש להביא בחשבון כי שיעורי חזרה נמוכים אלה מתקיימים בשיטה שבה הענישה על המתה היא חמורה יחסית (ודאי חמורה מהאפשרות שהייתה מודרכת רק על יסוד שיקולי מניעת היחיד) – הן בפועל (כלומר מי שביצע המתה מרצה עונש מאסר ממושך) והן בכוח (הוא מודע לכך כי אם יחזור ויהרוג הוא צפוי לעונש מאסר ממושך). עם זאת ניתן להניח בזירות כי אילו היה השיקול של מניעת היחיד שיקול הענישה היחיד, היה ניתן להסתפק בענישה קלה מזו הקיימת. ברור כי גישה כזו אינה באה בחשבון, ולו רק בשל ההתעלמות הכרוכה בה משיקולי הענישה האחרים.

קשה מאוד, כנראה בלתי אפשרי, לאפיין ולחבוק באמצעות רכיב יחיד את אישיותו של העושה ואת מסוכנותו. הערכת מסוכנות אינדיווידואלית, גם כאשר מביאים בחשבון את כל המידע שיש על אותו אדם, היא קשה ובעייתית במיוחד. היא כרוכה גם בחדירה הנרחבת ביותר לפרטיות וחשופה במיוחד לחשיבה סטראוטיפית ולדעות קדומות. שיקול דעת רחב לרשות השופטת והתמקדות במניעת העושה עלולים להצמיח רמת ענישה קלה למדי על עבירות של המתה, וזו עלולה להתפרש בציבור כמבטאת פיתות בערך של חיי אדם. מנגד, עלולה הערכה של מסוכנות מיוחדת של העושה להביא להחמרה מיוחדת בענישתו אף יותר מן המגיע הגמולי. מבחינה עקרונית אפשר שראויה יותר הפרדה בין ענישה – שהגמול קובע את הסף העליון שלה בהחלט – לבין אמצעי מנע המאפשרים בידודו של העושה גם למעלה מזה על יסוד מסוכנות מיוחדת, ובלבד שגם המשטר של אמצעי מנע כפוף להגבלות חוקתיות, ושמצבו של המבודד נבדק לעיתים מזומנות שמא אין הוא מסכן עוד את הציבור, וניתן אז לשחררו.¹¹⁷⁴ כל עוד אין מבחינים בין עונשים לבין אמצעי מנע בהקשר זה, יש חשש שבתי המשפט יחרגו מן המגיע ה"גמולי" על יסוד שיקול של מסוכנות.¹¹⁷⁵ אכן, ההצדקה באנגליה למאסר עולם חובה היא לאפשר להחזיק בכלא אנשים מסוכנים שיש סכנה לשחררם.¹¹⁷⁶ עולה מן המקובץ ההתאמה של עונש מאסר עולם למקרה של המתה חמורה ואף הצורך בתגובה עונשית כזו.

1173 ראו Eser, לעיל ה"ש 653, בעמ' 105.

1174 זהו הרעיון העומד מאחורי ס' 4(5) לאמנה האירופית לזכויות אדם, ולפיו: "Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful".

1175 על ההבחנה בין אמצעי ענישה לאמצעי מנע ראו Helen Silving, "Rule of Law" in Criminal Justice, in Essays in Criminal Science 77, 107–108, 113–119 (1961); גנאים ההבחנה בין הצדקה-בדין לבין

סליחה-בדין, לעיל ה"ש 25, בעמ' 361–365.

1176 ראו גם עניין Thynne, Wilson and Gunnell, לעיל ה"ש 1055; ועניין Stafford, לעיל ה"ש 1058, פס' 87.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 237

(3) העונש על עבירת הרצח – מאסר עולם כעונש חובה נוקשה, במובחן מעונש חובה גמיש/מותנה או עונש מירבי?

העונש של מאסר עולם חובה נולד במסגרת פשרה פוליטית שהייתה נחוצה לשם ביטול עונש המוות ושרד ככזה בזכות הפעלת סמכות החנינה של הכתר או הנשיא.¹¹⁷⁷ בחוק ההמתה האנגלי מ-1957 הוסמך השופט להמליץ פומבית על תקופת המאסר המינימלית שבסופה יצווה מזכיר המדינה על שחרור.¹¹⁷⁸ ברור כי לא כל מי שמורשע ברצח, כמעט לפי כל אפיון פרטני שניתן לתאר, ראוי לפי שיקולי הענישה המקובלים, ובעיקר הגמול, למאסר עולם,¹¹⁷⁹ כפי שעולה גם מהפרקטיקות המקובלות אצלנו ובמדינות אחרות,¹¹⁸⁰ והדין צריך לשקף זאת. ביטולו של מאסר העולם כעונש חובה יגדיל את המקרים שבהם תהיה הודאה באשמה כפי שקרה בוויקטוריה שבאוסטרליה. הדבר מאפשר כאמור גם להרחיב את נפח האיסור – את היקף המקרים שבהם עונש של מאסר עולם כעונש מרבי הוא עונש הולם מבחינה נורמטיבית.

זאת ועוד, יש עדיפות ברורה לשיטה שבה את דינו של אדם חורץ גוף שיפוטי, הנהנה מקביעות והחשף פחות להשפעתם של הלכי רוח וביקורת חריפה של הציבור, הפועל בגלוי ובפומבי, המספק הנמקה, ויש עליו ביקורת שיפוטית וציבורית, לעומת שיטה שמעבירה את ההכרעה בפועל לאדמיניסטרציה של משרד המשפטים ולסמכות החנינה של הנשיא, שאין להם המאפיינים שתוארו. גם יתרונותיה הפוטנציאליים של שיטה כזו, הנסמכת על הפרדה אקוסטית, נשחקו במציאות הישראלית. הגיונה של גישת ההפרדה האקוסטית בנוי על אפשרות התקיימותה במציאות. אולם רוב הציבור המתעניין – הן ציבור העבריינים והן משפחות הקורבנות – ידע שעונש מאסר העולם על רצח הוא רק "פרוֹפורמה", וכי קיימים סידורי חנינה שמהם נהנים חלק גדול מן המורשעים ברצח, גם אם לא ידעו אל נכון את מידת כלליותה של השיטה ואת ההסדרים המדויקים. בין שהציבור הרחב היה ער לפרקטיקה שנהגה אז ובין שלא, מצב זה נמשך רק עד שבא הנשיא ויצמן, ובשל סירובו להמשיך במשחק נחשפה בציבור ה"שיטה". בעקבות זאת הוסדרה קציבת העונש של מאסר עולם במסגרת חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001.¹¹⁸¹ אולם גם למנגנון הקבוע שם – המלצה של ועדת שחרורים מיוחדת המועברת לנשיא לפי בקשתו של הנידון לאחר חלוף שבע שנים מתחילת המאסר – יש מן החסרונות של קציבה על ידי גוף שאינו מחויב לדרכי הפעולה של בתי משפט ולא תוס השיפוטי, וההכרעה בסופו של דבר אינה בידיו של גוף שיפוטי או מעין-שיפוטי אלא בידי הנשיא. גם באנגליה נוצר מצב דומה כאשר להפרדה האקוסטית – הציבור באנגליה חשב שהעונש בפועל על רצח (אחרי החנינה) הוא עשר שנים, כשהוא למעשה חמור יותר. מלבד שאלת ההיתכנות המעשית של הפרדה

¹¹⁷⁷ על אנגליה, Report of the Committee on the Penalty for Homicide, לעיל ה"ש 1034, בעמ' 8; The Law Reform Commission of Victoria, Report No. 1, The Law of Homicide in Victoria: The Sentence for Murder (Chairperson: Prof. Louis Waller, 1985).

¹¹⁷⁸ ראו Report of the Committee on the Penalty for Homicide, לעיל ה"ש 1034, בעמ' 9.

¹¹⁷⁹ ראו שם, בעמ' 16–17.

¹¹⁸⁰ על אנגליה ראו גם, Martin Wasik, A.-G.'s Ref. No. 33 of 1996, [1997] 2 Cr.App.R.(S) 10, 17; Sentencing in Homicide, in RETHINKING ENGLISH HOMICIDE LAW 167 (Ashworth & Mitchell eds., 2000).

¹¹⁸¹ ס"ח תשס"א, 410, בפרק ה' לחוק.

אקוסטית בזמננו ניתן לתהות גם עד כמה ראוי מבחינה עקרונית להסתמך עליה כאשר היא מבוססת על פער בין הכתוב עלי חוק לבין המתרחש בפועל. מצב דברים של אי-התאמה בין החוק כנורמה עלי ספר החוקים לבין החוק בפועל אינו מוסיף כבוד והערכה לשיטה המשפטית.

יש שיקולים נוספים לטובת ביטול עונש החובה:¹¹⁸² הסדר נורמטיבי ללא עונש חובה משפר את אפשרויות השיקום של האסיר, מאפשר לבטא כהלכה בענישה את הרמות השונות של חומרת המעשה, והצורך בתגובה עונשית עליו מונע מרשויות מנהליות צורך לברר שאלות מורכבות – עובדתית ומשפטית – של נתונים מקילים שאינם באים לידי ביטוי במשפט בשל היעדר רלוונטיות, כאשר הן אינן בנויות לכך. ביטול מאסר עולם חובה מונע גם צורך לטעון מלאכותית טענות של הגנה מלאה, כאשר למעשה מצב הדברים מצדיק רק הפחתה בעונש.

לא נראה שביטול עונש החובה יפגע בהרתעה (במובן הפחדה). השיקול העיקרי גם של רוצחים מחושבים ומתכננים הוא הסיכוי להתחמק מעונש ולא חומרת העונש. רוצחים כאלה גם בקיאים במצב המשפטי ויודעים לא רק מה החוק אומר אלא גם את מהי הפרקטיקה הנוהגת בעניין אנשים כמותם שתהיה מחמירה מאוד. הם גם יודעים שמאסר העולם הקיים אינו מאסר עולם בפועל. באשר לאנשים שפועלים בהתרגשות עזה – ספק רב אם ניתן להשפיע עליהם בהפחדה. ספק גם אם הממיתים בספונטניות במצב שאינו של התרגשות עזה שוקלים קונקרטיים את העונש הצפוי להם בטרם ביצעו. ואכן, בדיקה שנעשתה באנגליה הראתה שברוב מקרי ההמתה שנכנסו שם לגדרי עבירת הרצח העושה אינו שוקל את העונש.¹¹⁸³ במסגרת הדיון בהרתעה יש להביא בחשבון לא רק את ההשפעה הישירה בשעת מעשה אלא גם את ההשפעה העקיפה, הקבועה, על ההתייחסות לחיי אדם. ואולם, הניסיון בוויקטוריה העלה כי ביטול עונש החובה לא היה כרוך בגידול מספרי של מעשי רצח. על כל אלה יש להוסיף כי ההרתעה מושפעת מן ההסדר בכללותו: ברמת העונש המרבי ההצעה מחמירה עם חלק מהמקרים יותר מן הדין הקודם. מבחנה האמיתי של מערכת המשפט יהיה רמת הענישה שתוטל בפועל במסגרת שיקול הדעת – בתוך מסגרת העונש ההולם – שיימסר בידיה. בידיה יהיה הדבר למנוע תחושה בציבור בדבר זילות חיי אדם, ובשל גישתו העקיפה של בית המשפט העליון לסוגיה זו (בפרשנות שנתן לעבירת הרצח) יש טעם רב להאמין שבית המשפט יעמוד היטב במבחן. ניתן גם להבטיח בהסדר שייקבע בחוק לעניין קציבת העונש שהתקופה לריצוי בפועל של מי שנגזר עליו מאסר עולם תהיה ארוכה במיוחד, וששחרורם של נידונים כאלה יהיה ברישיון בלבד, עד סוף חייהם.

חשש אחר הוא מתגובה ציבורית קשה לביטול עונש החובה. בעיקרון צריך להביא בחשבון את הרגישות הציבורית שבאנגליה הייתה לה השפעה רבה על ההתפתחות, אך אין להיחפז באימוץ הסדרים פגומים – נוגדי-עקרונות – בגלל חשש מתגובה ציבורית. צריך להביא בחשבון שלציבור יש תחושת צדק, וכי גם החמרת יתר הנתפסת כלא צודקת עלולה לערער את אמון הציבור במערכת המשפט. התשובה לחשש מפני גזרי דין קלים מדי, לרבות סטיות לא מוצדקות אל מתחת למינימום, היא האפשרות לערער לבית המשפט העליון, שגילה רגישות גדולה מאוד לחשיבות הערך ולהיבט המניעה הכללית שבענישה.

1182 ראו 1, The Law Reform Commission of Victoria, Report No. 1, לעיל ה"ש 1177, בעמ' 6-7.

1183 ראו שם.

פרק רביעי: הדין לפני תיקון מס' 137, הליקויים שבו וקווים לדין הרצוי כפי שבא לידי ביטוי בתיקון מס' 137 | 239

לטיעון שלפיו יש להותיר את עונש החובה על כנו כדי להגן על הציבור מפני אנשים מסוכנים אין יסוד, שכן רוב הרוצחים אינם כאלה. שיעור המועדות אצל רוצחים נמוך משל עבריינים אחרים.¹¹⁸⁴ עם כל זאת, בטרם מבטלים את עונש החובה, יש לתת את הדעת לענישה על עבירות חמורות אחרות ולוודא שאין אינפלציה של מאסרי עולם שם, שכן על רקע כזה ביטול עונש החובה עלול באמת להתפרש כפיחות בערך של חיי אדם. אחד השיקולים באנגליה לטובת שימור עונש החובה היה ריבוי עבירות אחרות שיש עליהן מאסר עולם כעונש מרבי כדי לסמן הבדל. בד בבד עם ביטול עונש החובה הנוקשה יש מקום להנהגת עונש חובה מותנה, המבוסס על התקיימות רכיבים מחמירים מוגדרים, אך מותנה בכך שבמכלול נסיבות המעשה יש דרגה גבוהה במיוחד של אשמה. כאשר מכלול הנסיבות הללו שולל את ההשפעה מגבירת האשמה של הרכיב המחמיר, מתבטלת החובה, והמעשה עובר מן הצורה המוחמרת אל הרצח הבסיסי, שצמוד לו מאסר עולם כעונש מרבי. השאיפה למנוע פגיעה נוספת בערך החיים היא שעומדת ביסוד הנטייה לשמר את העונש של מאסר עולם (לא כחובה קשיחה) על אף אופיו הגבולי מבחינת האכזריות שבו והמסר האנטי-שיקומי שבו. שימור העונש של מאסר עולם משקף גם שייתכנו מקרים – אומנם יוצאי דופן – שבהם האדם לא ישוחרר לעולם, שאם לא כן, מדובר רק בהפרדה אקוסטית, שבהקשר זה נראית לא ראויה. ממילא העונש של מאסר עולם ממלא תפקיד של הרתעה מול קלקולציה אפשרית שמאסר, אפילו ארוך, הוא בכל זאת סיכון כדאי (למשל בחישוב שעורך רוצח שכיר).

שימור מאסר העולם מתחייב ממש בשיטה שלנו על רקע קיומם של עונשים לעבירות אחרות של עשרים שנות מאסר. לא נראה שיש מקום לקבוע לעבירת הרצח עונש מאסר קצוב שהוא ארוך יותר. אם אכן מותירים את העונש של מאסר עולם על כנו, יש להנחות את בית המשפט באפיון המקרים החמורים במיוחד, בשל ההבדל המהותי שבין עונש בלתי מוגבל לבין עונש מוגדר.

1184 ראו שם, בעמ' 11.

